[Thème 1 : Le Droit, c'est quoi ?](#)
[Thème 2 : Le Droit, les droits quelle différence ?](#)
[Thème 3 : Les mots du droit](#)
[Thème 4 : Le droit pour qui ?](#)
[Thème 5 : d'où vient le droit](#)

03 septembre 2026

Note : l'adresse universitaire fonctionne mal donc utiliser son mail perso si elle ne répond pas - elsa.burdin@gmail.com

⚠️ Un contrat stipule mais une loi dispose, precise, clarifie (mais ne stipule pas).

Les définitions sont à connaître par cœur. Le code civil est inversement a ne pas connaître par cœur. Seule les defs et les grands principes.

Thème 1 : Le Droit, c'est quoi ?

Le droit organise la vie en société, le licite et l'illicite. Il fournit des procédés et procédures.

Pourquoi le droit apparaît dans une societe ?
Distinguer le droit, la justice, la morale et l'équité.
Quelques termes de voc.

Introduction :
Def du Droit v1 : Le droit est un ensemble organisé de règles destinées à régir la vie en société et dont le respect est assuré par des institutions publiques. En d'autres termes, le droit intervient à deux moments clés : en amont, le droit édicte des règles pour organiser les rapports humains (le droit donne les règles du jeu, dit ce qui est possible de faire ou non, comment le faire, etc…), et en aval, le droit organisé un système de sanctions (civiles, pénales ou disciplinaires) pour eviter le recours à la justice privée et à la violence.

Porter plainte = droit pénale (vis-à-vis de la societe)
Assigner au tribunal = droit civil (vis-à-vis de la victime)

Cette Definition est un point de départ qui a besoin d'être compléter, ce n'est pas qu'un catalogue de règles mais aussi un système (système jusk). Les règles sont organisées entre elles, sont articulées et se combinent. Les normes sont articulées entre elles, interprétées par des institutions (juges) et appliquées à des situations concrètes.
Les règles sont organisées selon un principe hiérarchique.
Ce qui différencie le juriste des autres humains est sa façon de voir les choses : il adopte une méthode personnelle de lecture des faits, en se concentrant sur des éléments juskment

pertinents. Il leur donne une qualification jusk. Cette qualification jusk entraîne l'application dun regime jusk (corps de règles). Grâce à ça le juriste en déduit la solution.

I- Le Droit un phénomène social

A- Pourquoi le droit existe-t-il ?

Le droit devient necessaire dès lors quil y a plusieurs personnes et qui doivent coordonner leurs comportements. Le droit sert à fixer des **repères communs**. Il sert à repartir les pouvoirs et les responsabilités. Il protège certaines valeurs et propose des mécanismes de règlement des différents.

Ex : Robinson Crusoé n'a pas besoin de droit quand il est seul. Mais quand il y a Vendredi, il a besoin de règles.
S'il y a une règle il y a souvent besoin de penser à une sanction ou une menace de sanction pour le faire respecter.

Cest de l'interaction sociale que nait le besoin de règles. Cest de la Volonte de résoudre pacifiquement les conflits que nait le besoin d'établir des règles jusk.

Il y a un adage jusk : Ubi societas ibi us. « La où il y a une société il y a du droit »

B- Les fonctions du droit

La fonction générale du droit est d'ordonner les relations sociales. Cette fonction ce décline en plusieurs fonctions complémentaires :

- L'organisation : il attribu des compétence, défini des statut et encadré des échanges
- La prévention : il indique à l'avance les comportements autorisés, interdits ou obligatoires
- La protection : il garanti la protection et la sécurité des personnes, des biens, des libertés et des intérêts considérés comme essentiels
- La résolution de conflits : quand quelqu'un viol la règle il résout les conflits, ie il substitue une procédure et une Decision juridictionnelle à la violence
- L'expression de choix collectifs : a chaque époque le droit donne une priorité à certaines valeurs qui sont comprises comme importantes, primordiales par la societe

Le droit est à la fois un instrument de stabilité (il donne la règle) et de transformation sociale (il évolue avec les mœurs, la technique scientifique, les rapports économiques ou les choix politiques. Cest pourquoi le droit varie selon les pays et les périodes).

Le droit nest pas le seul système qui existe et possède des règles. Il y a aussi : la famille, la religion, les coutumes, l'armée, le langage, les jeux…

II- Le droit, la justice et les autres systèmes

A- Des notions proches mais distinctes

Dans le langage courant, les mots droit, loi, règle de droit et justice sont parfois employés comme des synonymes. Pourtant ils ne désignent pas tous la même réalité.

- Le droit désigne ici l'ordre jusk envisager dans son ensemble, ie des règles, des institutions, des procédures et des resonnements
- La règle de droit est une prescription ou une norme particulière appartenant à cet ordre jusk
- La loi est une catégorie de textes adoptée suivant une procédure déterminée. Elle est une source du droit mais elle n'en est pas l'unique
- La justice peut désigner une valeur : le Juste, mais peut désigner aussi l'institution qui est chargée de trancher les litiges et de juger les infractions

B- Le droit, la morale, la religion et les usages sociaux

Toutes les règles de conduites ne sont pas des règles jusk. En effet, la vie sociale est egalement structurée par la morale, la religion, la politesse, la bienséance… les frontières ne sont pas parfaitement étanches. Une même conduite peut être approuvée ou condamnée par plusiseurs systèmes à la fois.

Si le droit est bien un phénomène social, il nest qu'**un** phénomène social parmi d'autres, puisque les règles de droit ne sont pas les seules règles qui existent dans la société. Seule les règles de droit peuvent amener à être traduit devant la justice. Les usages sociaux ont pour finalité de respecter les codes dun groupe. S'ils ne sont pas respectés, la sanction est une désapprobation voir une exclusion d'un groupe.
Ce qui distingue nest pas le contenu de la regle mais l'appartenance ou non à lordre jusk et si oui ces consequences. La justice ne sanctionne qu'avec les règles de droit. Il ne condamne pas en fonction du reste.

Toutes les règles jusk ne coïncident pas forcément avec la morale. Ex : si quelqu'un vole mon portable. La règle de droit dit que dans le droit des biens, « en fait de meuble la possession vaut titre » donc ca veux dire que le fait d'avoir le portable donne le droit en théorie. La morale et le droit comdamnent le vole. Mais au bout de 30 ans, l'objet appartient au voleur, parce que le droit fait prévaloir la paix sociale, ce qui nest pas le cas en morale.

C- Droit et justice

Le droit et la justice entretiennent des liens étroits mais ne se confondent pas. La justice, entendue comme idéale, renvoie à ce qui parait juste ou équitable. Or, ce qui parait juste ou équitable dépend et varie selon les personnes, les sociétés et les époques. Aristote distinguait la justice commutative (celle qui recherche un équilibre arithmétique dans les échanges entre les personnes) et la justice distributive (celle qui s'intéresse à la répartition des avantages et des charges dans la collectivité et qui a pour objet la meilleure répartition des richesses et des charges entre tous les membres de la société. Elle se différencie donc de la justice commutative parce qu'elle se détache de la stricte égalité arithmétique pour suivre une voix correctrice et sociale).

Une regle peut être juskment valable sans pour autant correspondre à la conception personnel du juste de chacun. Les valeurs de justice influencent souvent la creation, l'interprétation et l'évolution du droit, notamment à travers les droits et libertés à valeur constitutionnelle. Cest pourquoi il est impossible de les séparer tout à fait.

Dire que le droit et la justice ne se confondent pas ne signifie pas que le droit est indifférent à la justice. Cela signifie que la validité jusk d'une règle et son appréciation morale sont deux questions distinctes.

Contrairement à la Justice, le droit est insensible à de telles considérations, il est loin d'être figé. En effet, il évolue constamment et ne peux pas être compris indépendamment d'une époque, d'une histoire ou d'une idéologie. Et c'est pour ça qu'on dit que le droit est porteur des valeurs de la société. Il arrive même que l'on puisse percevoir ces valeurs dans le texte lui même, parce que parfois le législateur énonce des objectifs à atteindre dans des dispositions constitutionnelles ou législatives, ou parce que le texte a pour objet l'inscription de ces objectifs dans une multitude de sources.

Ex : l'article 1 de la loi du 30/12/1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

D- Deux grandes conceptions du fondement du droit

Si le droit varie, qu'est-ce qui fait que le droit est légitime ?

Il existe plusieurs courant doctrinaux tentant d'expliquer pourquoi le droit est légitime.
Doctrine du droit naturel ≠ doctrine du droit positif

Pourquoi une regle jusk mérite-t-elle d'être obéie ?
Cette question de la légitimité du droit a divisée les auteurs. Deux de ces familles de pensées sont le droit naturel et le positivisme jusk.

Le droit naturel (Aristote, Grotius, St Thomas d'Aquin) :
Le fondement du droit réside dans des principes supérieurs, universels ou rationnels. Ces principes servent de mesure au droit positif (=droit en vigueur à un moment donné dans un espace donné).

Le positivisme jusk (Hobbes, Kelsen) :
La validité d'une regle dépend de l'appartenance de cette règle à un ordre jusk et est conditionné par son mode de production.

Le droit naturel dit qu'un droit injuste peut être tenu comme illégitime, voir ne pas mériter le nom de droit selon certains sous-courants. Pour les positivistes, le validité jusk et la valeur morale sans à analyser séparément. Ce qui compte est que la norme est été adoptée suivant la procédure déterminée et qu'elle soit conforme à la norme qui lui est supérieure.

Limites des deux théories :

- Droit naturel : difficulté à identifier des principes véritablement universels et une fois identifier connaître leur contenu exact.
- Positivisme jusk : le risque est de négliger totalement l'évaluation morale du contenu des normes si l'analyse reste purement formelle.

Chaque courant de pensée a ses énormes inconvénients.

Le droit naturel a d'abord été rattaché à un ordre de la nature ou à un ordre divin. Puis il est passé de Dieu à la raison humaine. Gratius l'a laïcisé. Cela a nourris la creation des droits fondamentaux, la DDHC, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948)…
Le positivisme jusk étudie le droit tel qu'il est posé et en vigueur dans un espace donné. Chez Kelsen, l'accent est mis sur la validité des normes au sein d'un système hiérarchisé. Pour lui le droit ce sont des normes mises les unes au dessous des autres. Le droit est ce qui est ordonné par l'État, il se réduit au droit positif, ie à l'ensemble des règles de droit en vigueur dans un État donné, à un moment donné.

Quelle que soit la conception que l'on adopte, le droit ne se confond pas avec la règle de droit. Le premier est plus large que la seconde. Et la règle de droit présente des caractéristiques qui lui sont propres, ce qui permet de la reconnaître.

04 septembre

III- Comment reconnaître une regle de droit ?

Le doctrine présente traditionnellement la règle de droit comme étant générale, impersonnelle, permanente, normative et obligatoire.

A- Une regle générale et impersonnelle

Lorsqu'on dit qu'une regle de droit doit être générale et impersonnelle, cela veut dire qu'elle vise des catégories abstraites de personnes, ou des situations abstraites. Le loi ne vise pas une personne nommément désignée. Elle peut concerner l'ensemble des citoyens ou seulement une catégorie de ceux-là (ex : réglementation sur une profession précise).

L'article 6 de la DDHC affirme que « la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Cette exigence n'interdit pas les différences de traitement dès lors qu'elles sont juskment justifiées. Lorsque l'on est dans la même catégorie, on est soumis au même régime jusk. Mais si on est dans des catégories différentes, on est dans différents régimes.

La loi est générale signifie qu'elle s'applique sur tout le territoire français. Mais il arrive qu'une règle est un champ d'application limité dans l'espace, dans le temps ou à une matière particulière. Mais même dans ce cas là, elle demeure générale parce qu'elle vise abstraitement toutes les personnes ou toutes les situations qui entrent dans son champ d'application. C'est cette absence d'individualisation qui permet de différencier la règle de droit d'une décision ou de mesures individuelles.

Ce caractère de règle générale et impersonnelle doit être combiné avec un deuxième caractère propre à la règle de droit : la permanence.

B- Une règle permanente.

La règle de droit a vocation à s'appliquer de manière continue à toutes les situations qui entrent dans son champ d'application pendant la période où elle est en vigueur. C'est pourquoi on peut dire qu'elle est permanente. Cela ne signifie pas qu'elle est éternelle : elle

peut être modifiée voire abrogée. Il y a même des lois qui ont été conçues avec une durée limitée (Lois en CDD). C'est notamment les normes expérimentales qui sont autorisées par l'article 37-1 de la Constitution (C37-1). Ex : la loi Veil de 1975 (légalisation de l'IVG) a été précédée par une loi d'expérimentation.

C- Une règle normative

Une règle est normative lorsqu'elle produit des effets jusk. Elle ordonne, elle interdit, elle autorise, elle attribue un pouvoir, elle reconnaît un droit, elle définit une catégorie ou elle fixe les conditions d'un régime jusk. Elle est alors normative. Le Conseil Constitutionnel (Conseil C) rappelle que « la loi a vocation à énoncer des règles et doit être revêtue d'une portée normative » (Decision « Avenir de l'École » du 21/04/2005). Ce qui veut dire qu'une simple déclaration d'intentions qui serait donc dépourvue d'effets jusk identifiables ne rempli pas cette fonction et c'est précisément pour cette raison que le Conseil C a refuser de considérer que la règle « l'objectif de l'école est la réussite de tous les élèves » (art. 1 loi « Avenir de l'École ») soit considérée comme une règle de droit.
Contre-Ex : art. 516 du CC « tous les biens sont meubles ou immeubles ». La portée normative est présente

D- Une règle obligatoire

La règle de droit s'impose dans les conditions fixées par l'ordre jusk. Sa violation ou sa méconnaissance peut entraîner une conséquence jusk organisée par les institutions publiques. La conséquences n'est pas forcément réductible à une peine :

- Le prononcé d'une nullité : nullité d'un acte irrégulier
- L'exécution forcée d'une obligation
- La réparation d'un préjudice par des dommages et intérêts
- Le prononcé d'une peine en matière pénale : prison, amende (compensation des dommages subis par la société)
- Le prononcé d'une sanction administrative ou disciplinaire

Dans la grande majorité des cas, la sanction est punitive mais pas seulement, elle peut également être préventive. Elles sont là pour prévenir l'existence d'un trouble ou d'une atteinte. Ex : Huis-clos de l'art. 435 du Code de Procédure Civil (CPC). Cet article dispose : « le juge peut décider que les débats auront lieux ou se poursuivront en Chambre du Conseil, s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée ou si toutes les parties le demande, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ».

La sanction peut toucher des actes (ex : nullité) ou des personnes (ex : réparation).

Le caractère obligatoire de la règle de droit permet d'influencer, de guider la conduite des individus. Le caractère obligatoire doit être formulé avec prudence car certaines règles définissent des notions, habilitent sans ordonner directement, et pourtant toutes ces règles sont jusk parce qu'elles appartiennent à l'ordre jusk et parce qu'elles produisent des effets reconnus par l'ordre jusk.

Le caractère obligatoire de la règle de droit n'a pas toujours la même force. Il faut donc distinguer les règles impératives des règles supplétives de volontés.

- Règles impératives : s'imposent aux personnes ; qui ne peuvent que la respecter et ne peuvent pas l'écarter par un accord contraire.

Art. 6 CC l'exprime pour les lois intéressant l'ordre public et les bonnes mœurs. Il dispose que « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs ». ie qu'il est impossible pour les individus de déroger à ces règles par une manifestation de volonté contraire.

- Règles supplétives : s'appliquent seulement si les personnes n'ont pas manifesté une volonté contraire, ce qui veut dire que les partis peuvent prévoir une solution différente. Mais s'ils ne prévoient rien, la règle supplétives complète automatiquement leur silence. Alr or, s'il est possible de prévoir autre chose que ce que la règle de droit édicte, et donc s'il est possible d'écarter la regle écrite, il est necessaire de prévoir autre chose. A défaut, c'est la règle supplétive qui s'appliquera. Elle serait alors de même caractère obligatoire que la règle impérative.

Ex : au mariage on peut faire le contrat (séparation des biens par exemple). Mais s'il n'y en a pas, le régime légal s'applique.

Thème 2 : Le Droit, les droits quelle différence ?

Le mot droit possède deux sens complémentaires. Il désigne tout d'abord le droit objectif, ie l'ordre jusk dans son ensemble. On peut aussi l'entendre au sens de droits subjectifs, ie des prérogatives que cet ordre jusk reconnaît aux personnes.

Objectifs :

- Distinguer le Droit objectif et les droits subjectifs
- Savoir que les droits subjectifs trouvent leur fondement dans le Droit objectif
- Être capable de définir le patrimoine
- Être capable de distinguer l'actif du passif dans le patrimoine
- Être capable de différencier les droits patrimoniaux, des droits extra-patrimoniaux
- Être capable de distinguer les droits réels et personnels (ou de créances)
- Savoir ce que sont les droits intellectuels et leur situation particulière

Introduction :
Il y a un mot, deux sens. Le terme droit est polysémique. Dans une première acception (=sens), le Droit (ou Droit objectif) désigne « l'ensemble des règles socialement édictées et sanctionnées qui s'imposent aux membres de la société ». Dans une seconde acception, les droits désignent les prérogatives reconnues à une personne déterminée. Le Droit objectif pose les règles, les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles qui résultent de ces règles.

I- Du Droit objectif au droits subjectifs
A- Le Droit objectif

Le Droit objectif est l'ensemble des règles jusk qui sont applicables dans une société donnée à un moment donné. Ces règles encadrent aussi bien les relations entre les personnes privées que l'organisation des institutions et l'exercice de la puissance publique. Le Droit objectif est envisagé de manière abstraite. Il ne décrit pas seulement la situation d'une personne déterminée, il fixe les catégories, les conditions et les effets jusk à partir desquels les personnes pourraient ensuite faire valoir leurs droits.
Ex : la DDHC appartient au Droit objectif. Les règles qu'elle contient permettent aux personnes d'invoquer concrètement les droits et libertés subjectifs.

Cette approche très générale doit être complétée par une approche plus concrète. On ne parle plus du Droit mais des droits, ie ceux dont sont titulaires les sujets de droits, les personnes. Ce sont les droits subjectifs.

B- Les droits subjectifs

Les droits subjectifs sont définis comme « une prérogative accordée par le Droit et permettant à une personne d'user d'une chose ou d'exiger d'une autre personne l'exécution d'une prestation ».

Ils sont donc les prérogatives individuelles que le Droits objectif reconnaît à une personne afin de lui permettre de protéger un intérêt, d'utiliser un bien, d'accomplir un acte ou d'exiger d'une autre personne l'exécution d'une prestations.

Leur titulaire est un sujet de droit, ie une personne physique ou morale (dotée de la personnalité jusk).

Le droit de propriété, le droit de créance, le droit au respect de la vie privée ou le droit de vote sont tous des exemples de droits subjectifs. Mais ils n'ont ni le même objet, ni le même régime. En revanche, ils confèrent tous à leurs titulaires une exclusivité sur un bien déterminé, qu'il s'agisse d'une chose, d'une image, etc. Tous les droits subjectifs ne sont pas nécessairement des biens patrimoniaux. En effet, certains droits peuvent être évalués en argent et donc entrer dans le patrimoine. Mais certains autres droits sont attachés à la personne, à son état ou à une fonction familiale. Dans ces cas-là les droits sont dis extra-patrimoniaux. Souvent les droits subjectifs sont utilisés par leurs titulaires et dans l'intérêt de ce dernier, mais il peut arriver que le droit subjectif soit utilisé par le titulaire dans l'intérêt de quelqu'un d'autre, comme l'autorité parentale.
L'autorité parentale illustre le fait qu'un droit subjectif n'est pas toujours exercé dans le seul intérêt de son titulaire. L'art. 371-1, al. (alinéa 1 du CC. définit l'autorité parentale comme (pas a apprendre) « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle confère donc aux parents des prérogatives jusk, mais ces prérogatives sont inséparables des devoirs de protection, d'éducation et de respect de la personne de l'enfant ». Alr or, l'autorité parentale appartient aux parents et ce jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité. Pour assurer également son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.

Les droits subjectifs peuvent être classés suivant plusieurs critères mais pour bien comprendre toutes ces distinctions, il est nécessaire de commencer par distinguer le patrimoine, les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux.

II- Patrimoine, droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux

A- La notion jusk de patrimoine

En Droit, le patrimoine ne désigne pas la fortune d'un individu mais désigne quelque chose d'abstrait, un contenant. Ce contenant est une universalité jusk qui comprend les rapports de droits appréciables en argent dont une personne est titulaire ou débitrice. Le patrimoine comporte deux ensembles indissociables : l'actif et le passif. L'actif comprend les biens, les créances, tandis que le passif inclut les dettes, les charges et les obligations évaluables en argent. Le patrimoine peut être rempli, vide ou endetter mais toujours présent.

B- La théorie classique du patrimoine

La construction classique élaborée au XIXe siècle par Aubry et Rau rattache le patrimoine à la personnalité jusk. Elle conduit à retenir 4 propositions (à connaître par cœur) :

- Toute personne possède un patrimoine même si son actif est nul et son passif important
- Seuls les personnes physiques ou morales possèdent un patrimoine (en droit français seules les personnes sont dotées d'un patrimoine, donc les animaux qui ne sont pas des personnes et soumis au régime jusk des biens n'ont pas de patrimoine, ils ne peuvent hériter d'une somme d'argent ou autre, contrairement à d'autres systèmes jusk. L'art 514-14 du CC reconnaît les animaux comme « des être vivants doués de sensibilité » mais il précise que « sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens »)
- Le patrimoine envisagé comme universalité n'est pas librement cessibles entre vifs même si ses éléments peuvent l'être. S'il est incessible du vivant du titulaire, tel n'est plus le cas lorsque la personne physique ou morale disparaît. Lorsque la personne physique meurt, son patrimoine est transmis à ses héritiers qui peuvent ou non l'accepter. Si les héritiers acceptent la succession, ils acceptent le patrimoine dans son entier (passif et actif). En France il existe l' « acceptation à concurrence de l'actif net ». Ça permet à l'héritier de limiter le payement des dettes à la valeur des biens qu'il reçoit.
- Chaque personne ne possède en principe qu'un patrimoine

09 septembre

⚠️ Fonds de commerce (toujours avec un S)

Le fonds de commerce contient tout ce qui est mobilier mais pas ce qui immobilier.

C'est doctrinal mais structurant. C'est très important pour le droit civil, notamment parce que même si elles sont structurantes, c'est à l'aune (par rapport à) de ces comparaisons que l'on remarque les changements actuels notamment avec les notions actuelles de « patrimoine d'affectation ».

Le terme patrimoine revient partout, tout le temps et de plus en plus, en étant utiliser pour des choses différentes du patrimoine jusk comme : « patrimoine culturel » (ensemble des biens immobiliers ou mobiliers relevant de la propriété publique ou privée qui présente un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique), « patrimoine commun de l'humanité » (concept de droit public), « patrimoine de la nation » (droit de l'environnement, indique que les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et les paysages, mais également la qualité de l'eau, de l'air, les espèces animales, végétales, la diversité et les équilibres biologiques, l'eau, les sons et odeurs caractérisants les milieux naturels, font partie du patrimoine commun de la nation), « patrimoine mondial » (désigne les sites culturels et naturels qui possèdent une valeur universelle exceptionnelle et qui nécessites donc leur protection et leur préservation), « patrimoine sensoriel des campagnes » (à cause des citadins et surtout les parisiens qui ne supportent pas les bruits et odeurs de la campagne), « patrimoine constitutionnel européen » (désigne la création d'un espace jusk commun entre les Etats européens), « patrimoine numérique des personnes » (désigne l'ensemble formé par les données numériques qui sont rattachées à une personne, tout cet ensemble peut être transmit à la mort de l'utilisateur par la rédaction de directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication des données à caractère personnel, apres le décès de cette personne). Cest aussi une notion cardinale en droit. La notion jusk de patrimoine nest pas celle utilisée dans le langage courant, alr or ca ne fait pas nécessairement référence à la fortune d'un individu, puisque le patrimoine est un contenant. Cest piur cette raison que le patrimoine est défini par la doctrine comme « l'ensemble des rapports de droit appréciables en argent qui ont pour sujet actif ou passif une même personne et qui sont envisagés comme faisant partie d'une universalité jusk ». Toutes les définitions présentent le patrimoine comme une universalité, ie un ensemble indissociable de droits et de charges, alr or un actif et un passif, même si la substance de ce patrimoine est susceptible de variée. La patrimoine est l'exemple type de l' « universalité de droit » (établie par la loi) s'opposant à l' « universalité de fait » (établie par volonté). Contrairement à l'universalité de droit, l'universalité de fait est composée uniquement d'actifs, qu'il s'agisse de biens corporels ou incorporels, sans inclure de passifs. L'universalité du patrimoine est très importante car en découle des conséquences.

C- Les conséquences d'une notion évolutive.

L'universalité explique « le droit de gage général des créanciers ». Selon les art. 2284 et 2285 de CC, « le débiteur répond en principe de ses engagements sur ces biens présents et à venir. Les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, sous réserve des causes légitimes de préférences et des règles d'insaisissabilités. » Alr or, ces articles offrent une sécurité au créancier, en effet, ils possèdent un droit de gage général sur le patrimoine de leurs débiteurs, ce qui signifie qu'ils peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur n'importe quel bien du débiteur. N'importe quelle dette sera payée à l'aide de n'importe quel bien présent dans le patrimoine du débiteur au moment où la mesure d'exécution forcée sera mise en œuvre. Cette affirmation doit immédiatement être tempérée puisque le législateur a voulu protéger certains biens comme : la résidence principale de l'entrepreneur individuel (c'est une personne physique qui exerce une activité commerciale, agricole, artisanale ou libérale. Depuis la loi du 16/8/2015, cette protection de la résidence principale est de plein droit (pas besoin de la demander)).
L'article 2285 dispose quand à lui « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il N'y ait entre les

créanciers des causes légitimes de préférence. ». ie que s'il y a plusieurs créanciers non payés, ils sont placés sur le même pied d'égalité s'ils non pas de sûretés. Les créanciers qui ne disposent d'aucune sûreté sont les créanciers chirographaires. Ils passent après ceux possédant des sûretés, comme une hypothèque.

La seconde conséquence est qu'il faut bien comprendre que la composition du patrimoine varie continuellement : par exemple, un bien peut sortir du patrimoine et être remplacé par une somme d'argent ou par une créance de prix. Dans certaines hypothèses, cette substitution jusk est appelée « subrogation réelle ». C'est la cas d'une indemnité d'assurance suite à la perte d'un bien.

Le principe d'unicité du patrimoine connaît des adaptations. En effet, depuis la réforme du statut de l'entrepreneur individuel, les éléments utiles à l'activité professionnelle forment un patrimoine professionnel qui va être distinguer du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel.

Il y a une distinction à voir pour saisir la notion de patrimoine : c'est la distinction entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux.

D- Droits patrimoniaux et droits extra-patrimoniaux

Les droits subjectifs peuvent être classés suivant qu'ils entrent ou non dans le patrimoine.

10 septembre

Attention un droit extra-patrimonial ne devient pas patrimonial simplement parce que sa violation donnerait lieu à des dommages et intérêts (D&I). Les droits extra-patrimoniaux ne sont pas évaluables en argent. Exemple : le droit au respect de la vie privée reste attaché à la personne mais la créance de réparation (D&I) qui est nee de sa violation est patrimoniale. Une personne peut autorisé certaines utilisations de son images ou de son nom, et parfois contre rémunération, sans pour autant céder définitivement le droit de la personnalité lui-même.

III- Les principales catégories de droits patrimoniaux

Il convient ici d'étudier plus précisément les différentes catégories de droits patrimoniaux.

A- Les droits réels

Def : Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir jusk direct et immédiat sur un bien.
Il met donc en relation une personne et un bien, tout en produisant des effets à l'égard des tiers.
Ça permet au titulaire d'exercer des prérogatives qui vont lui procurer tout ou partie de l'utilité économique de la chose.
Le droit réel par excellence est le droit de propriété : c'est le droit le plus complet, parce qu'il donne à son titulaire les trois pouvoirs (usus (utiliser), fructus (percevoir les fruits), abusus (détruire))
On distingue traditionnellement :

- Les droits réels principaux
    - Propriété
    - Usufruit
    - Droit d'usage
    - Servitude
    - Certains autres droits de jouissance
- Les droits réels accessoires ou les sûretés réelles
    - Hypothèque (garantie le paiement d'une créance)

Les droits réels ont des caractéristiques :
- Ils sont opposables à tous (erga omnes)
- Ils sont absolus

Ces droits réels confèrent un droit de préférence (permet au titulaire d'être payé prioritairement sur la valeur du bien grevé. En cas de conflit entre un titulaire d'un droit réel et un titulaire d'un droit personnel sur un même bien, c'est le titulaire du droit réel qui sera préféré et donc c'est lui qui remportera le procès si le titulaire du droit personnel n'arrive pas à prouver son droit) et un droit de suite (permet de suivre et de revendiquer la chose entre les mains de celui qui la possède aujourd'hui. Alr or, le propriétaire de l'objet pourra agir en revendication en quelques mains qu'elles se trouvent). Les droits réels ne peuvent concerner que des biens existants et individualisés contrairement aux droits personnels. Jusqu'à récemment la doctrine présentant les droits réels comme en nombre limité. La jurisprudence a admis la possibilité de créer des droits réels en l'absence d'une disposition législative expresse. Les juges l'ont notamment fait à partir de l'arrêt « Maison de Poésie » du 31/10/2012 rendu par la troisième chambre civile de la Cours de Cassation. Dans cet arrêt, les juges ont en effet affirmés que « le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien ».

B- Les droits personnels ou droits de créances

Le droit personnel ou droit du créance permet à une personne appelée créancier d'exiger d'une autre personne appelée débiteur, l'exécution d'une prestation. C'est donc un rapport de droit, il y a en effet un sujet actif du droit (créancier) et un sujet passif (débiteur) et un objet de droit (prestation). Donc il s'agit d'un droit de créance du côté du sujet actif et d'une obligation du côté du sujet passif.
Exemple : en achetant une voiture on attend du garage qu'il transfère la voiture, ce qui est exigeable dès que le payement a été fait
Cela s'oppose aux droits réels.
Dans le droit personnel ou droit de créance, il y a un rapport qui s'établit de façon indirecte entre la personne et le bien et il y a un rapport entre deux personnes, l'une exige de l'autre une prestation. Cette prestation peut donner lieu a trois choses :
- Des obligations de donner

Du latin dare : signifie transférer la propriété de (comme lors d'une vente)
- Des obligations de faire
- Des obligations de ne pas faire

Le droit personnel crée donc principalement un rapport entre deux personnes, il produit un effet relatif. En effet, seul le débiteur est tenu d'exécuter la prestation au profit du créancier.

En principe il ne confère pas de droit de suite sur un bien sorti du patrimoine du débiteur. Alr or, le titulaire d'un droit personnel ne pourra exiger l'exécution forcée de l'obligation que sur le patrimoine de son débiteur et seulement dans la limite de la composition que ce dernier avait au moment de la poursuite. Si le débiteur a vendu un bien avant que le créancier engage de poursuite, le bien ne peut pas être saisi dans les mains du tiers acquéreur, sauf collusion frauduleuse.
Le droit personnel ne confère aucun droit de préférence. Cela signifie que le créancier ne possède qu'un droit de gage général sur le patrimoine de son débiteur, au sens de l'article 2285 du CC. Si le patrimoine de son débiteur est insuffisant pour satisfaire l'ensemble des créanciers chirographaires, ces derniers seront payés au marc le franc (= les créanciers seront payés au prorata de leur créance et sans préférence entre eux).
Le droit personnel est relatif, contrairement au droit réel qui est absolu. Dire que le droit personnel est relatif veut dire qu'il n'aurait d'effets qu'à l'égard du débiteur de la prestation engagée. Le créancier dépourvu de sûretés particulières, est qualifié de créancier chirographaire, il dispose donc du droit de gage général prévu aux articles 2284 et 2285 du CC. En cas d'insuffisance de l'actif, il va entrer en concours avec les autres créanciers chirographaires, et il ne bénéficiera d'aucune préférence particulière.
La distinction entre les droits n'est pas si nette que ca car il existe une catégorie intermédiaire : les droits intellectuels.

C- La situation particulière des droits intellectuels

Les droits intellectuels protègent notamment les créations de l'esprit, les inventions, les marques et d'autres objets immatériels. Ils ne se laissent pas toujours enfermer dans l'opposition classique entre droits réels et droits personnels.
Par exemple, en droit d'auteur, il faut distinguer deux dimensions : les droits patrimoniaux d'exploitation permettent d'autoriser ou d'interdire certaines utilisations de l'œuvre. Ils peuvent être céder dans les conditions prévues par la loi et sont limités dans le temps. Le droit moral protege le lien personnel de l'auteur avec son œuvre. Ainsi l'article L121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle precise que le droit moral « est perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Il est néanmoins transmissible à cause de mort, aux héritiers de l'auteur.

Le droit se compose de plusieurs catégories. C'est pourquoi on présente le droit comme composé de summa divisio. Exemple : les sujets de droits, les objets de droits, les personnes, les choses, les actes jusk, les faits jusk… Tout ça sont des catégories qui se subdivisent encore, par exemple : la catégorie des biens regroupe les immeubles et les meubles (art. 526) mais les immeubles se divisent entre les immeubles par natures, les immeubles par destination ou par l'objet auquel il s'appliquent, et les meubles se divisent aussi entre meubles par nature ou en meubles par anticipation.
Les catégories sont importantes, elles permettent d'appliquer tout un ensemble de règles particulières. Par exemple : le droit de propriété est un droit patrimonial et les droits patrimoniaux constituent des biens parce que les biens peuvent être des choses ou des droits. Puisqu'il constitue un bien, il est évaluable en argent, a une valeur et peut être cédé soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. En revanche, le droit à l'honneur ou le droit au respect de la vie privée, qui sont des droits extra-patrimoniaux, ne sont pas évaluables en argent, donc ils ne peuvent pas être cédés. Ils ne sont donc pas des biens et ne rentrent pas dans le patrimoine mais leur violation donnera lieu à l'allocation de D&I et ils peuvent même être sanctionnés sur le volet pénal.

11 septembre

Évaluation de connaissance :
A/B/A/B (8/8)
PR/PC/E/PI/E (5/5)
P/Accessoire/Suite (3/3)
V/F/Venfant/Intermediaire/opposable à tous (5/5)
Total = 21/21
Cas pratique : ils auront tous 13 333€ et il reste 1€. 40000€ d'actif 100000 de passif. Art. 2285 CC « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ». Que des chirographaires. « Au marc l'euro » répartition proportionnelle. Formule : (créance/passif)*actif

Resume les faits pertinents (dont qualification des faits pertinents). Question de droit. Majeure (=règle de droit qui s'applique). Mineure (=confrontation de la majeure aux faits). ET LA SOLUTION.

Thème 3 : Les mots du droit

Les objectifs de ce thème :

- Retenir que le vocabulaire jusk possède un sens précis
- Distinguer les faits bruts de leur qualification jusk
- Savoir construire un raisonnement jusk sous la forme d'un syllogisme
- Savoir expliquer le rôle respectif des parties dans la qualification
- Savoir identifier les limites imposées aux juges en particulier par l'objet de litiges et le principe du contradictoire
- Savoir distinguer un adage, d'une présomption et d'une fiction jusk

Introduction : Le Droit, une langue à part entière
Le Droit utilise des mots que l'on rencontre aussi dans le langage courant, mais il attribue à ces mots un sens technique. Ce sens peut être un peu plus étroit, plus large, voir simplement différent. En Droit, une approximation de vocabulaire, va conduire à choisir la mauvaise catégorie jusk et donc appliquer une mauvaise règle. Apprendre le Droit consiste à apprendre une méthode de traduction, il faut partir d'une situation concrète, sélectionner les faits pertinents, les exprimer en notions jusk (qualifier), identifier la règle applicable puis en déduire une solution après l'avoir confronté aux faits. Alr or, le Droit à son propre langage, et il est absolument nécessaire de le connaître et de le maîtriser.

1- Des mots au sens courant aux termes jusk
A- Un vocabulaire spécialisé
Un terme jusk doit être compris uniquement suivant la définition et suivant le régime jusk que lui donne le droit. Le contexte est donc extrêmement essentiel pour comprendre.
Exemple : le mot caution désigne dans le langage courant une somme d'argent laissée en garantie, mais en droit il s'agit d'une personne qui s'engage envers le créancier à payer la

dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement en droit des sûreté, sert à désigner le contrat qui organise cet engagement.

B- Des notions proches mais non interchangeables
Ex : résilier c'est arrêter pour l'avenir, résoudre c'est a effet rétroactif. Le nullité est quand c'est mal formé dès l'origine.
Toutes les distinctions en Droit ont des distinctions concrètes, parce qu'elles déterminent les conditions de la sanction. Elles déterminent aussi ses effets dans le temps. Possiblement elles vont déterminer aussi s'il y aura des restitutions à faire ou non. Voir cela peut déterminer aussi les pouvoirs du juge. Il faut comprendre qu'il faut faire preuve de rigueur et de précision. L'application du Droit repose avant tout sur un travail de qualification jusk.

II- Qualifier les faits pour trouver la règle
A- Définition de la qualification jusk
La qualification jusk est l'opération intellectuelle qui consiste à rattacher un fait, un acte, une personne ou une relation à une catégorie reconnue par le droit. Elle transforme les faits bruts en faits juskment pertinents.
Dire qu'une personne a remis une somme d'argent à une autre décrit un fait, si on veut le qualifier juskment il faut savoir plus de choses : dire qu'il s'agit d'un prêt, d'un don manuel, du paiement d'une dette ou d'un dépôt constitue une qualification jusk. Chaque qualification entraîne un régime jusk (jusk) différent. La qualification jusk ne doit jamais être négligée. Cest elle qui conditionne l'application dun corps de règles et la solution.

B- Le but de la qualification : la détermination du régime jusk adéquat
A qualifications jusk identiques, correspondent un même régime jusk. Cela signifie que si on qualifie mal les faits, on n'appliquera pas le bon régime jusk et donc la solution sera fausse et/ou pourra être facilement contredite. Le but de la qualification réside donc dans l'application d'un corps de règles particulier, spécifique, capable de régir la situation concernée.

C- Une méthode singulière en 4 étapes
1) Sélectionner les faits utiles, pertinents

Il faut donc écarter les détails qui n'ont aucune incidence jusk. Alr or ceux qui ne sont pas utiles pour arriver à la solution du cas.

2) Traduire ces faits en notions en catégories jusk

Contrat ? Faite ? Dommage ? Mariage ?

3) Rechercher le régime attaché à la qualification retenue
4) Vérifier que les conditions de la règle sont réunies.

D- Un cas guider : la relation de Jeanne et Jules

Faits : Jeanne reproche à Jules d'entretenir une relation avec une autre personne et elle veut savoir ce qu'elle peut faire. Jeanne est très pieuse.

Pour savoir quoi faire, il faut qualifier la relation. Mais les faits ne sont pas assez précis.

Méthode : si deux hypothèses sont envisageables parce que les faits sont imprécis, il faut mettre les deux puis en choisir une.

Si on considère qu'ils sont concubins, l'article 515-8 du CC s'applique, lequel défini le concubinage comme étant « une union de fait caractérisée par une vie commune, stable et continue » mais s'ils sont simples concubins, la conséquence jusk de cette qualification est qu'il n'y a aucun devoir légal, général de fidélité.
Le PACS se caractérise par une vie commune, une aide matérielle et une assistance réciproque. L'article 515-4 du CC ne formule pas de devoir légal de fidélité à côté des obligations de vie commune, d'aide matérielle et d'assistance réciproque. Il n'y a pas non plus ici d'obligation de fidélité entre partenaires.
Dans le mariage, l'article 212 du CC prévoit un certain nombre de devoirs pour les époux. Il s'agit du respect, de la fidélité, du secours et de l'assistance entre époux. La conséquence jusk de cette qualification est qu'une infidélité est susceptible de constituer une violation d'un devoir du mariage et donc de constituer une cause de divorce.

Faits : Jeanne et Jules sont mariés depuis deux ans.

Jules contrevient ici à un devoir du mariage, il commet une faute. Mais même dans le mariage, l'adultère n'entraîne pas automatiquement un divorce pour faute, encore moins au tort exclusif de son auteur.
Selon l'article 242 du CC le juge apprécie si une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage rend intolérable le maintien de la vie commune.
La qualification ouvre le raisonnement, **elle ne dispense jamais de verifier toutes les conditions de la règle et de justifier votre raisonnement et votre solution.**
Les juristes suivent un raisonnement particulier pour arriver à la solution. Ce raisonnement s'appelle le syllogisme jusk.

III- Le syllogisme jusk
L'application des règles de droit s'établit donc au terme d'un raisonnement particulier. Raisonnement que l'on appelle syllogisme jusk. Il se divise en trois étapes : il consiste à trouver un fondement (majeure), puis à l'appliquer à une situation de fait (mineure) pour en déduire une solution (conclusion).

A- Les trois temps du raisonnement
Étape de la majeure : quelle est la règle applicable ?
Le contenu de la majeur est l'énonciation de la règle applicable et déterminer ses conditions d'application. La majeure est nécessairement une règle de loi mais pas nécessairement un article de loi. Certaines règles de droits proviennent par exemple d'arrêts.
Étape de la mineure : les faits remplissent-ils les conditions de la règle identifiée ?
Le contenu de la mineure est l'application précise de la règle aux faits. IL FAUT DÉMONTRER CE QUI EST AFFIRMÉ.
Étape de la conclusion : quelle est la solution ?
Le contenu de la conclusion est la déduction de la conséquence jusk. Si un fait manque, il faudra envisager les deux solutions.

Le syllogisme n'est pas une récitation mécanique. Il oblige à justifier le choix de la règle, à confronter chacune de ses conditions aux faits et surtout à signaler les incertitudes. La conclusion doit répondre à la question posée sans affirmer quelque chose que ne permettrait pas d'envisager les informations disponibles.

B- L’application au cas de Jeanne et Jules

Majeure :

Nous partirons de l’hypothèse que le mariage de Jeanne et Jules a été valablement contracté. Ce faisant, ce mariage entraîne des obligations prévues à l’article 212 du CC. Cet article prévoit notamment que les époux se doivent fidélité au titre des obligations qui résultent du mariage. Si l’un des époux ne respecte pas l’un de ces devoirs, il est susceptible de commettre une faute qui entraînerait des conséquences jusk au nombre desquelles figure le divorce. Les cas de divorce sont précisés à l’article 229 du CC et parmi eux figure le cas du divorce pour faute. Le divorce pour faute est régi par les articles 242 et suivants du CC et il s’applique lorsque des faits imputables à un époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Mineure :

En l’espèce, Jeanne et Jules sont mariés. A ce titre, les époux doivent respecter un devoir de fidélité l’un envers l’autre. Or, Jules a été infidèle. Par conséquent, l’infidélité avérée de Jules peut constituer une violation du devoir de fidélité et entraîner le prononcé d’un divorce pour faute. Jeanne étant une personne très pieuse, on peut considérer que la fidélité est une chose très importante pour elle. L’infidélité de son époux est donc quelque chose de particulièrement grave pour elle. Il y a donc de fortes probabilités pour que de son pov la gravité de la faute commise par son mari rende intolérable le maintien de la vie commune et justifie le prononcé d’un divorce pour faute.

Conclusion :

Par conséquent, même si les faits demeurent soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, il est probable au vu des faits que les juges prononcent le divorce pour faute aux torts exclusifs de Jules.

Ce qu'il ne faut surtout pas faire :

1) Commencer par la solution souhaitée puis chercher une règle pour la justifier
2) Énoncer une règle sans vérifier toutes ses conditions d’application
3) Répéter simplement les faits dans la mineure sans les confronter à la règle de droit
4) Employer un terme courant à la place d’une qualification jusk pertinente
5) Croire que citer un arrêt suffit à faire une démonstration
6) Présenter comme certaine une conclusion qui dépend d’un fait non établi ou du pouvoir d’appréciation des juges
7) Terminer par « ca dépend du pouvoir souverain des juges du fond »
8) Oublier de conclure

La qualification jusk doit être menée avec rigueur et sérieux. Qui se charge de cette qualification ?

IV- Qui qualifie les faits ?

A- Les parties et leur avocat

Les parties exposent les faits, elles formulent leurs prétentions. Les avocats sélectionnent les faits utiles. Ils les qualifient et invoquent les règles susceptibles de soutenir les demandes ou la défense et ils vont proposer une argumentation jusk. Les qualifications proposées orientent le débat. Mais elles ne lient pas tout le temps le juge.

B- Le juge à travers son devoir de qualification
L'article 12, alinéa 1 et 2 du Code de Procédure Civile (CPC), impose aux juges de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties. Alr or, il est possible qu'un prétendu contrat de prêt soit requalifié par le juge si le contenu de ce contrat révèle une autre opération.
Le Juge n'est pas libre de transformer le litige. En effet, son pouvoir de qualification va s'exercer dans un cadre défini, non seulement par les prétentions des parties, mais également par les faits soumis au débat. Il y a une exception encadrée par la loi : on dit que, pour les droits dont elles ont la libre disposition, les parties peuvent, par un accord expresse, lié le juge par les qualifications et les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

16 septembre

C- Les trois limites essentielles qui touchent au litige
Ces limites touchent à l'objet du litige. En effet, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. Le Juge ne choisit pas en principe ce qui lui est demandé. Le pouvoir de qualification du juge ne lui permet pas de modifier librement l'objet du litige. Suivant l'art. 4 du CPC, l'objet du litige « est déterminé par les prétentions respectives des parties ». L'art. 5 du même Code ajoute que le Juge doit se prononcer « sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ces règles imposent en réalité une double obligation : répondre à chaque chef de la demande sans accorder plus que ce que demande les parties ni autre chose que ce qu'elles demandent. Ces règles combinées permettent de distinguer trois irrégularités traditionnellement désignées par des expressions latines : *infra petita*, *ultra petita* et *extra petita*.

1- *Infra petita*

Ne pas répondre à toute la demande. Le Juge statut infra petita lorsqu'il omet de se prononcer sur un chef de demande dont il était régulièrement saisi. Par exemple : il statut sur le remboursement du capital réclamé mais ne réponds pas à la demande distincte portant sur les intérêts.
⚠️On ne parle pas ici d'une partie qui ne serait pas satisfaite de la réponse donnée par le Juge. On parle ici d'une prétention qui n'aurait pas reçue de réponse.
Il ne faut pas confondre l'infra petita avec le déni de Justice. En effet, l'infra petita est une omission portant sur une décision déterminée. Le déni de Justice correspond plus largement au refus de juger ou à la négligence de traiter une affaire en état d'être jugée. Il est visé à l'art. 4 du CC et à l'art. L141-3 du COJ.

2- *Ultra petita*

L'ultra petita revient à accorder plus que demander. Le Juge statut ultra petita lorsqu'il dépasse quantitativement une prétention. Par exemple : si une partie réclame 10 000€, le Juge ne peut pas lui en accorder 15 000. Il n'a pas le droit de le faire quand bien même il pense que cela est justifié.

Petite nuance : le juge peut appliquer une autre qualification jusk, ou un autre fondement de droit, sans statuer ultra petita dès lors qu'il ne dépasse pas l'objet et l'étendu de la prétention soumise.

3- *Extra petita*

C'est accorder autre chose. Le Juge statut extra petita lorsqu'il modifie qualitativement l'objet du litige et qu'il accorde une mesure qui n'était pas demandée. Alr or, il ne s'agit plus d'accorder une quantité supérieure à ce qui était demandé, mais de substituer une prétention différente à celle formulée par les parties. Dans un arrêt du 5 avril 2005, la première chambre civile de la Cour de Cassation a censuré une décision qui avait attribué à une épouse, en plus de la contribution aux charges du mariage qui était demandée, la jouissance gratuite du domicile conjugal. Cette mesure supplémentaire n'avait pas été demandée. Par conséquent, la juridiction avait modifié l'objet du litige. (N° de pourvoi : 02-19559)

Il y a une deuxième limite essentielle : le Juge doit statuer sur tout ce qui est demandé mais seulement sur ce qui est demandé.
Enfin : si le Juge envisage de relever d'office un moyen de droit (il n'a pas été saisi par les parties. Un moyen de droit est un élément que le Juge n'a pas le droit d'ignorer même s'en être saisi.), il doit permettre aux parties d'en débattre contradictoirement. Le principe du contradictoire est toujours respecté.

En termes de qualification, il y a un principe important à retenir. Ce principe veut que les juges ne soient pas liés par les termes utilisés par les parties. art. 12 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : le Juge doit « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé ». Ainsi, si les parties ont dénommé contrat de bail alors que c'est un contrat de vente, les Juges vont requalifier le contrat en contrat de vente malgré l'appellation donnée par les parties. Cette requalification a des conséquences jusk très importantes. En effet, cela entraîne l'application du régime jusk de la vente et non pas celui de la location. L'alinéa 3 prévoit que « il ne peut changer la dénomination ou le fondement jusk lorsque les parties, en vertu d'un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat. Le dernier alinéa dit que « le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncer ». Alr or, les parties peuvent demander au Juge de statuer en équité, et pas en appliquant les règles de droits (regjus).

Ce qu'il faut retenir : Grâce à la qualification des faits, le Juge donne à la réalité une connotation jusk mais parfois la qualification jusk va plus loin que la réalité. En effet, il y a des hypothèses dans lesquelles le droit consacre un mensonge pour préserver la paix sociale, ou le droit affirme une vérité bien trop générale pour être exacte (fiction jusk). Exemple : l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » ne signifie pas que tout le monde connaît toute la loi, mais que celui qui ignore la loi de bonne ou mauvaise foi ne peut pas se prévaloir de son ignorance pour échapper à l'application de la loi. C'est ce qu'on appelle une fiction. Cette fiction est justifiée par la nécessité et le principe d'égalité des citoyens devant la loi. Ihering disait de la fiction que « c'est un mensonge technique consacré par la

nécessité. Elle facilite donc le progrès et le rend possible à une époque où les forces feraient encore défaut à la science pour donner au problème sa véritable solution ».
Exemple : il y a une fiction juridique qui est la présomption de paternité.

D- Droit et équité

En principe, le Juge tranche suivant les regjus. Ça veut dire qu'il ne peut pas écarté une règle applicable au seul motif qu'une autre solution lui semblerait plus équitable. L'équité peut néanmoins jouer un rôle lorsque la loi y renvoie, lorsqu'une notion laisse une marge d'appréciation ou dans le cadre particulier de l'amiable composition.

V- Adage, présomption et fiction jusk

A- Des techniques différentes

Le droit ne se contente pas de qualifier les faits. Le droit utilise aussi des formules et des techniques qui facilitent l'application des règles.
L'adage est une formule brève qui exprime une idée ou une règle générale. (Ex : Nul n'est censé ignoré la loi)
La présomption est une technique qui consiste à déduire un fait inconnu à partir d'un fait connu. (Ex : la présomption de paternité)
La fiction jusk est de considérer ou de tenir juridiquement une situation pour acquise afin de produire un effet déterminé mais sans la confondre avec la réalité matérielle. (Ex : infans conceptus : veut que l'enfant conçu soit réputé comme né chaque fois qu'il en va de son intérêt)

18 septembre

B- Adage : Nul n'est censé ignorer la loi

Cet adage exprime une nécessité liée au fonctionnement du droit. En effet, il postule que dès lors qu'une règle est régulièrement publiée et entrée en vigueur, cette règle doit pouvoir être opposée à ses destinataires. Ce qui veut dire que la seule ignorance de son existence, quand bien même cela correspondrait à la réalité, ne suffit pas à en écarter l'application.

C- L'enfant simplement conçu et la présomption de paternité

L'adage latin « infans conceptus » signifie que l'enfant simplement conçu est tenu et réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. L'application de cet adage est subordonnée à la naissance effective de l'enfant. La présomption de paternité obéit à une autre logique. C'est là pour l'établissement d'un mode de filiation paternelle. C'est la loi qui organise les cas d'exclusion, de rétablissement et éventuellement de contestation de la filiation paternelle.

Auto-évaluation :

Garantcaution/cautiondepot de garanti/nullité 2/6

	Qualifier	2
	Majeure	3
	Mineure	4
	Conclusion / solution	5
	Ennoncer des faits	1

6/6

1- Oui, il le doit
2- Non, il est le seul qui qualifie
3- Se limiter aux demandes et à la loi Respect du principe du contradictoire
4- Uniquement si la loi le lui permet ou que les partis le saisissent comme amiable compositeur
3,75/5

1- Infra petita
2- Ultra petita
3- Extra petita
3/3

14,75/20

Thème 4 : Le droit pour qui ?

L'idée du thème est que les règles jusk ont nécessairement pour but de régir des comportements, donc elles ont necessairement des destinataires. Plus exactement les règles jusk ont pour destinataires des sujets de droits. C'est la personnalité jusk qui leur permet d'être titulaires de droits et d'obligations. La personnalité jusk doit être différenciée de la capacité jusk, alr or le fait d'être titulaire de droits et d'obligation doit être distinguée de la capacité de les exercer soit même.

Objectif :

- Être capable de distinguer un objet de droit et un sujet de droit
- Être capable de distinguer et définir la personnalité jusk a la capacité jusk
- Être capable de distinguer des personnes physiques des personnes morales
- Être capable de dire dans quelles conditions on acquiert la personnalité jusk et dans quelles conditions on la perd
- Savoir distinguer des situations tendancieuses : distinguer l'absence de la disparition
- Savoir expliquer et détailler les conditions de l'adage infans conceptus

Introduction - Les destinataires de la regjus
Les règles jusk (regjusk) sont là pour régir des comportements et organiser des rapports sociaux. Donc nécessairement elles ont des destinataires que l'on appelle sujets de droits

(sujjus). Il s'agit des personnes physiques et des personnes morales. Un sujjus peut être titulaire de droits et d'obligations. Il peut être propriétaire d'un bien, créancier ou débiteur, conclure un contrat, agir en justice. A l'inverse, un objet de droit (objus) n'est pas titulaire de droits, ne peut pas être titulaire de droits, mais il est l'objet d'une prérogative exercée par un sujjus. Un sujjus peut exercer ces droits et obligations à l'égard d'un autre sujjus ou d'un objus.

I- Prolégomène : Sujjus, personnalité et capacité jusk

Prolégomène = introduction

A- La personnalité jusk (persjus) comme distinction entre les sujjus et les objus

Les personnes physiques (persp) sont tous des êtres humains. Les personnes morales (persm) quand a elle sont des groupements ou des institutions auxquelles l'ordre juridique reconnaît une personnalité distincte de celle de leurs membres. Il s'agit par exemple de certaines sociétés, des associations déclarées, des syndicats, collectivités territoriales, établissements publics…
La distinction repose sur la persjus parce que seuls les sujjus possèdent la persjus. Alr or, les choses, biens et valeurs économiques ne sont pas des persjus. Donc ils ne disposent pas eux-mêmes de droits et obligations.
Def : la persjus est « l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations ». C'est grâce à la persjus qu'il est possible d'avoir un patrimoine, conclure des contrats, être responsable, agir en justice…
La persjus d'une persp existe pendant toute sa vie. Elle reste la même. En revanche, la capacité d'une personne physique varie.

B- Persjus et capacité jusk : une indispensable distinction

Ce qui varie avec l'âge ou avec une mesure de protection jusk n'est pas la persjus. Il s'agit de la capacité jusk (capjus). La capjus recouvre deux choses : la capacité de jouissance (capjou) et la capacité d'exercice (capex). La capjou est l'aptitude à être titulaire d'un droit, alors que la capex est l'aptitude à l'exercer soit même.
Ex : un mineur possède la persjus et il peut être propriétaire ou hériter. Toutefois il ne peut pas accomplir seul tous les actes relatifs à ses droits. Dans le même sens, une mesure de protection prononcée pour un majeur, va limiter son aptitude à exercer certains droits ou faire certains actes mais sans supprimer sa persjus.
Le reconnaissance de la persjus a tout être humain n'a pas été linéaire dans l'histoire. En France, le décret du 27/4/1848 a aboli l'esclavage. Puis en 1854, la mort civile a été abolie à son tour. La mort civile privait certains condamnés de droits civils durant leur vie. Alr or, le prononcé de cette sentence conduisait à considérer ces condamnés comme morts, bien que vifs, ce qui entraînait des conséquences très importantes (dissolution du mariage, succession ouverte, plus rien de faisable). Aujourd'hui, tout être humain, en France, acquiert la persjus dans les mêmes conditions de naissance. La persjus n'est susceptible de varier qu'entre persp et persm.

II - L'acquisition de la persjus des persp
A- Le principe : naître vivant et viable

En droit français, la simple conception ne suffit pas pour conférer la persjus. En effet, cette derniere est acquise à la naissance, à la double condition que l'enfant naisse vivant et viable. La naissance vivante suppose que l'enfant ait manifesté des signes de vie. La viabilité désigne son aptitude à poursuivre une existence autonome, détachée (physiquement) de sa mère. Elle fait l'objet d'une appréciation médicale au regard de la situation concrète. Alr or, cela signifie que l'enfant doit naître avec tous les organes nécessaires et suffisamment constitués pour lui permettre de vivre. La déclaration de naissance à l'état civil ne crée pas la persjus. En effet, elle constate et rend opposable un événement déjà réalisé. Ce qui veut dire qu'une déclaration tardive n'empêche pas par elle même l'acquisition de la persjus si toute les conditions sont réunies. Par conséquent, avant la naissance, l'embryon et le fœtus ne sont pas des persjus. Cela ne signifie pas qu'ils sont traités comme le serait n'importe quelle autre chose. Il bénéficient en effet d'une proctection particulière. Ainsi l'art 16 du CC garantit le respect de l'être humain, dès le commencement de sa vie. De la même façon. Le droit de la bioéthique encadre notamment la recherche, l'assistance médicale à la procréation et les atteintes susceptibles d'être portées à l'embryon. En droit interne, le législateur assure la protection de l'embryon en interdisant le clonage mais également en encadrant strictement les expérimentations ou l'interruption de grossesse. En France, l'IVG peut-être pratiquée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, alr or 16 semaines après le premier jour des dernières règles. L'IVG est également conditionnée au souhait de la mère uniquement. Mais d'autres cas dépassent les 14 semaines : interruption médicale de grossesse (risque pour la mère ou fœtus mal formé comme la trisomie 18).
Depuis la loi constitutionnelle du 8/3/2024, l'art. 34 de la Constitution garantit la liberté de la femme de recourir à une IVG dans les conditions déterminées par la loi.
La CEDH considère également que l'embryon a un statut particulier. En effet, la CEDH refuse de considérer l'embryon comme un bien au sens du protocole additionnel n°1, tout en admettant que le sort de l'embryon relève du droit au respect de la vie privée de la donneuse ayant servie à la FIV.
L'art. 79-1 du CC, distingue l'enfant né vivant et viable puis décédé, pour lequel sont établies un acte de naissance puis un acte de décès, de la situation dans laquelle un acte d'enfant sans vie est dressé. Cet acte d'enfant sans vie mermet une reconnaissance a l'État civil, mais l'attribution d'un nom ou de prénom n'emporte pas a elle seule des faits jusk liés à la persjus. Cet art precise lui-même que « cette inscription de prénom et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non. Tout intéresse pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question. »
Par exeptions, la persjus va débuter avant la naissance pour remonter jusqu'à la conception de l'enfant.

B- L'exception : l'application de la maxime infans conceptus

C'est l'abréviation de ladite maxime. Cette maxime signifie que l'enfant simplement conçu est tenu pour né chaque fois qu'il y va de son intérêt. Cela revient à considérer un enfant simplement conçu comme étant déjà né. Cela permet notamment à un enfant simplement conçu d'hériter d'un proche. Mais cette possibilité est évidemment conditionnée. Il faut impérativement que l'enfant naisse viable et vivant par la suite. Cette même logique se perçoit dans certains arrêts. Par ex, la cour de cassation (CCas) a reconnu l'existence d'un droit à réparation lorsque l'événement dommageable est survenu avant la naissance, sous

réserve que les conditions propres à l'action soient réunies. C'est ainsi que la CCas à allouer une indemnisation à l'enfant pour réparer son préjudice moral du fait de la mort accidentelle de son père avant sa naissance. Cela a été fait dans la deuxième chambre civile le 14/12/2017. Elle a fait la même chose pour la mort d'un futur gp dans un arrêt du 11/2/2021. La maxime infans conceptus ne confère pas exactement une persjus générale dès la conception. Elle produit un effet favorable et rétroactif dans l'intérêt de l'enfant à la condition déterminante qu'il naisse vivant et viable.
Ex : art. 725 et 906 du CC.

III - L'acquisition de la persjus des persm
La persm permet de donner des droits et obligations à un groupement distinct de ses membres. Il peut ainsi disposer d'un patrimoine propre, conclure des contrats, employer du personnel, agir en justice et possiblement engager sa responsabilité. Toutes les réunions de personnes ne possèdent pas automatiquement la persm. La persm naît lorsque les conditions prévues pour la catégorie concernée sont remplies.

A- Une acquisition différenciée
Pour les sociétés, l'acquisition de la persm provient de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La société devient une personne différente de ses associés.
Pour les associations régies par la loi de 1901, l'acquisition de la persm est liée à la déclaration et à la publicité de cette association suivant le régime légal applicable à l'association. La conséquence est que l'association qui est déclarée et rendue publique acquiert cette persm et une capjus encadrée par la loi.

La méthode pour savoir si un groupement possède la persm : il va falloir identifier sa catégorie, puis vérifier si les conditions d'acquisition fixées par les textes sont remplies.

B- Une capacité encadrée
La persm n'est pas identique dans son exercice à la persjus des persp. Une persm agit par l'intermédiaire de ses organes ou de ses représentants et dans le cadre des règles qui lui sont applicables. L'art. 1145 alinéa 2 du CC énonce que « la capacité des persm est limitée par les règles applicables à chacune d'elles et en particulier par leur objet social ».
Les sociétés sont des contrats. Cela veut dire qu'elles existent même sans la persjus. Si elles respectent les conditions nécessaires à leur création, il y a une société, mais cette société n'a pas la persm. Donc elle ne pourra pas signer de contrat en son nom, elle ne pourra pas embaucher, agir en justice. Ce n'est qu'au moment de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS), que la société aura la persm et qu'elle deviendra pleinement indépendante des associés qui la composent.
La persjus des associations est un peu plus complexe. Il faut en effet distinguer les associations simplement déclarées, qui n'ont qu'une capacité restreinte, et les associations qui obtiennent la reconnaissance d'utilité publique. Elles ont une capacité étendue par rapport aux premières, mais elle reste limitée. En effet, elles ne peuvent pas acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles poursuivent.

Une persm peut-elle se prévaloir de droits de la personnalité ?

25 septembre

Cas pratique guidé de Moodle :

1- En principe le Juge n'est pas lié par la qualification donnée par les parties. En effet, celui-ci, aux termes de l'art. 12 du CPC, il doit même donner ou restituer leur exacte qualification aux faits sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
2- Il peut à la condition que la qualification ne corresponde pas à la réalité.
Correction sur Moodle

Suite du cours :

Pendant tres longtemps on a considéré que seules les personnes humaines pouvaient se prévaloir de tels doigts. (Respect de la vie privée…) Mais peu à peu les frontières bougent. C'est ainsi que les persm se sont vues reconnaître un droit à la protection de leur nom et de leur domicile, à la tranquillité, d'agir en diffamation et même de revendiquer leur liberté d'expression. Le mimétisme des persm vis-à-vis des persp néanmoins n'est pas complet puisque la première chambre civile de la CCas a, dans un arrêt du 16 mai 2018 (17-11210), refusé de reconnaître une vie privée dont le respect est assuré par l'article (ark) 9 du CC. Les juges ont affirmer que « si les perm disposent notamment d'un droit à la protection de leur nom, de leur domicile, de leur correspondance et de leur réputation, seules les persp peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens de ark 9 du CC ». Cela vaut en droit interne, mais les frontières sont moins nettes en droit de l'Union ou en droit européen puisque la CEDH reconnaît plus facilement l'extension de telles prérogatives aux perm. Par un arrêt, la CJUE, a le 14/2/2008 affirmer que « il ressort de la jurisprudence de la CEDH qu'il ne saurait être considéré que la notion de vie privée doive être interprétée comme excluant les activités professionnelles des personnes physiques comme des personnes morales ». Il y a une nouvelle dynamique qui se prolonge même sur une nouvelle question, c'est celle de la persjus de la nature. La vision moderne a conduit à considérer que la nature était une ressource et plus encore une ressource commune. Mais aujourd'hui cette vision n'apparaît plus suffisante et certains plaident pour doter la nature de la persjus. Certains pays l'ont fait et ont reconnu la qualité de sujet de droit à la nature. C'est le cas de la Nve-Zélande.

IV- La perte de la persjus des persm
La durée statutaire d'une société en France ne peut pas accéder 99 ans et ce conformément à ark 1838 du CC. Cette limite ne signifie pas que toute société disparaît nécessairement 99 ans après son immatriculation. En effet, la durée de la société (sotsé) peut être prorogée dans les conditions légales. La dissolution d'une sotsé ne fait pas disparaître immédiatement la persm. En effet, celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation.

V- La perte de persjus des persp
A- Le décès
Persjus de persp prend fin au décès. Le décès médicalement constaté est ensuite enregistré dans un acte de décès établi par l'officier d'état civil. Le décret du 2/8/2005 fixe les critères de la mort à propos des conditions relatives au prélèvement d'organes. Il s'agit du constat médical du décès. Ark R.1232-1 du Code de la Santé Publique, dispose que si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivant sont simultanément présents. Premièrement,

l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée. Deuxièmement, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral. Troisièmement, absence totale de ventilation spontanée. Lorsque la personne est assistée par ventilation mécanique et qu'elle conserve une fonction hémodynamique, ark R.1232-2 du Code de la Santé publique prévoit une autre procédure : prévoit qu'il faut soit deux électroencéphalogrammes nuls et areactif espacés d'au moins quatre heures, soit une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique pour avoir le constat médical de la mort. La fin de persjus n'efface pas toute protection. En effet, le respect du au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes doivent être traités avec respect, dignité et décence. Le principe est donc la mort cérébrale de la personne. Mais il y a des situations dans lesquelles il est impossible de savoir avec certitude si la personnes est morte ou vivante (notamment l'absence et la disparition).

B- La disparition

La disparition correspond à l'hypothèse dans laquelle une personne a disparu dans des circonstances de natures à mettre sa vie en danger et où le corps n'a pas été retrouvé. Dans ce cas là, le décès peut être judiciairement déclaré sans attendre les délais qui ont cours avec le regime de l'absence. Le jugement déclaratif de décès tient lieu d'acte de décès et il produit tous les effets attachés à la mort, ce conformément aux ark 88 et suivants du CC. La delcaration judiciaire de décès peut être demandée par le procureur de la République ou par toute personne intéressée. Apres transcription sur les registres de l'état civil, le jugement tient lieu d'acte de décès. Si la disparu reparaît, le jugement peut être annulé, mais certains effets ne disparaîtront pas : le mariage demeure dissous (conformément au regime decrit par ark 88 a 92 du CC).

C- L'absence

L'absence vise une personne qui a cessée de paraître à son domicile ou à sa résidence, dont on est sans nouvelle, mais sans circonstances particulières permettant de présumé immédiatement son décès. Le regime se déroule en deux phases :

- Le juge constate une présomption d'absence. La personne est alors <u>présumée vivante</u>, donc il y aura des mesures permettant de représenter ses intérêts et d'administrer ses biens qui seront ouvertes. La présomption d'absence est une présomption de vie. Alr or, le Juge des Contentieux de la Protection peut organiser la représentation de l'absent et l'administration de ses biens. Dans cette première phase, le mariage n'est pas dissous et si la personne reparaît ou donne de ses nouvelles elle pourra demander a ce quil soit mis fin aux mesures de représentation. Si son décès est établi, la succession s'ouvre. Si on as toujours pas de nouvelle, va débuter la seconde phase : la delcaration d'absence.
- La déclaration d'absence peut intervenir dix ans après le jugement ayant constaté cette présomption d'absence ou vingt ans après les dernières nouvelles en l'absence de jugement préalable et ce conformément à ark 122 du CC. Il doit transcrit, le jugement produit les effets du décès : ouverture de la succession et dissolution du mariage. En cas de réapparition, ark 129 du CC prévoit que le jugement peut être annulé, l'absent recouvre ses biens dans les conditions prévues par le CC, ark 130, mais son mariage reste dissous.

D- Des hypothèses différentes : suicides, refus de traitement et aide à mourir

Le suicide n’est plus une infraction pénale. En revanche, ark 223-13 du CC réprime la provocation au suicide, lorsqu’elle a été suivie d’un suicide ou d’une tentative (3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, porté à 5 ans et 75 000 euro d’amende lorsque la victime est un mineur de 15 ans).

Le refus ou l’arrêt d’un traitement en cas de maladie ou de blessure. Le médecin doit respecter la volonté du patient, mais après l’avoir informer des conséquences de son choix. Lorsque son choix met sa vie en danger, la décision doit être réitérée dans un délais raisonnable. Les traitements inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autres effets que le maintien artificiel de la vie, peuvent ne pas être entrepris, ou être suspendus au titre du refus de l’obstination déraisonnable. La nutrition et l’hydratation artificielle constituent des traitements.

02 octobre

En droit français, toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées relatives à la poursuite, à la limitation, à l’arrêt ou au refus de traitement. Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, la décision médicale doit respecter les directives anticipées. Et s’il n’y en a pas, il doit tenir compte du témoignage de la personne de confiance puis de la famille ou des proches dans le cadre de la procédure collégiale prévue par le code de santé publique.

Dans les conditions prévues à ark L1110-5-2 du Code de la santé publique et à la demande du patient, une sédation profonde et continue associée à une analgésie et à l’arrêt de traitement de maintien en vie peut être mis en œuvre jusqu’au décès mais seulement dans certains cas listés par cet ark :
1- Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable dont le pronostic vitale est engagé à court terme, présente une souffrance réfractaire au traitement
2- Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable
Cette sédation profonde et continue doit être distinguée de l’aide à mourir. La sédation vise à soulager de la souffrance alors que l’aide à mourir repose sur l’administration d’une substance létale. La loi du 18/8/2026 a créé un droit à l’aide à mourir, à ark L1111-12-1 du Code de la Santé Publique. Ce droit est réservé aux personnes majeures qui remplissent des conditions cumulatives, relatives notamment à la nationalité ou à la résidence, a une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, à la souffrance et à l’aptitude à exprimer une volonté libre et éclairée. Pour un patient mineur, hors d'état d’exprimer sa volonté, l’opposition des parents n’interdit pas nécessairement une limitation ou un arrêt des traitements. Le médecin doit rechercher l’accord des parents mais doit aussi agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il doit permettre aux parents d’exercer un recours en temps utile. Si les médecins considèrent que l’obstination n’est pas raisonnable, ils prennent la décision d’arrêter les traitements. Donc les médecins doivent prévenir suffisamment à l’avance pour que les parents puissent aller devant le conseil d’État, qui donne parfois raison aux médecins.
Dans la mesure où cette loi nécessite des textes d’application, elle n'est pas entrée pleinement en vigueur.

VI- Le statut du cadavre

La persjus s'éteint au décès, donc le cadavre n'est plus une personne mais une chose. Mais ce n'est pas une chose comme les autres. D'ailleurs, ark 16-1-1 du Code Civil affirme que le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort, et que les restes des personnes décédées, y compris leurs cendres doivent être traitées avec respect, dignité et décence. Ce principe est d'ordre public (le juge peut relever d'office) et il protége notamment l'intégrité et la dignité du corps. La CCas a ainsi interdit une exposition commerciale de cadavres plastinés dans l'affaire Our Body dans l'arrêt de la 1ere chambre civile le 16/9/2010 (n° de pourvoi 09-67.456). Les volontés du défunts relatives aux funérailles doivent être respectées. En leur absence, il appartient à la personne la mieux qualifiée pour pourvoir aux funérailles d'en décider. Après crémation, les cendres doivent recevoir l'une des destinations autorisées par ark L2223-18-2 du Code général des collectivités territoriales à savoir : la conservation de l'urne dans un lieu funéraire autorisé ou la dispersion des cendres dans un espace aménagé ou en pleine nature à l'exception des voies publiques.

VII- La science et le corps après la mort

Les utilisations scientifiques du corps demeurent soumises au respect, à la dignité et à des régimes de consentements distincts selon les differences hypothèses. Il faut dinstinguer le prélèvement d'organe, al recherche sur une personne décédée, le don du corps à l'enseignement médical et à la recherche ainsi que l'identification post-mortem.

Le prélèvement d'organe a finalité thérapeutique ou scientifique

Ark L1232-1 du Code de la Santé publique repose sur le consentement présumé (tout le monde est présumé donner son consentement) sauf si on exprime son refus de son vivant et notamment en s'inscrivant sur le registre national des refus. A défaut d'informations directement disponibles, l'équipe médicale recueille auprès des proches le témoignage de la volonté du défunt.

Pour la recherche

Pour la recherche sur une personne décédée en état de mort encéphalique (= cérébral), ark L1121-14 du Code de santé publique exige le consentement exprimé du vivant de la personne où attesté par le témoignage de sa famille. Si la personne décédée est mineure, le consentement relève en principe de chacun des titulaires de l'autorité parentale.

Le don du corps à des fins d'enseignement médical et de recherche

Ark L1261-1 du Coee de santé publique exige le consentement écrit du donneur majeur et impose aux établissements autorisés de traiter les corps confiés avec respect et dignité. Le consentement est révocable à tout moment.

L'identification post-mortem

Elle relève d'un régime particulier, à ark 16-11 du Code Civil qui régit l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques et ne peut être assimilée ni à un prélèvement d'organe, ni à un don du corps.

Thème 5 : d'où vient le droit

Les sources du droit

Au droit écrit, exprime par la loi et les règlements administratifs, il faut ajouter s regjus qui sont issues des usages et de la coutume. Les usages et le coutumes constituent des sources subsidiaires (ou secondaires) du droit. Il faudra s'interroger sur la place de la jurisprudence.
Jurisprudence (au moins 12 sens) = C'est l'ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux ⇒ application et interprétation du droit
La doctrine exerce une certaines influence sur la jurisprudence donc certains la considèrent comme une source indirecte du droit.

Objectif du cours :
- Être capable de distinguer les sources officieuses des sources officielles du droit
- Être capable de connaître la hiérarchie des sources et des normes dans les sources officielles
- Être capable de différencier le coutume et l'usage
- Savoir que la jurisprudence est dans la catégorie des sources officieuses du droit
- Savoir que les juges n'ont pas le droit de créer du droit

I- Les sources officielles

Ces sources officielles recoupent :
- Les sources supralégislatives
- La loi et les règlements
- La coutume

A- Les sources supralégislatives

Ces sources comprennent la Constitution, les traités et accords internationaux et le droit de l'UE.

1- La Constitution

La Constitution organise la dévolution et l'exercice du pouvoir. La France est régie par la Constitution de la Ve République du 4/10/58. Il faut lui ajouter le bloc de constitutionnalité. En effet, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16/7/71, le Conseil Constitutionnel a intégré à la Constitution un certain nombre de textes. La Bloc comprend aujourd'hui la Constitution du 4/10/58, la DDHC de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et les principes fondamentaux reconnus par les Lois de la République ainsi la Charte de l'Environnement de 2004 depuis une loi constitutionnelle du 29/5/2005. La décision du 16/7/71 est essentielle, elle a consacrée la valeur constitutionnelle du préambule et des textes auxquels elle renvoie.

2- Les traités et accords internationaux

Ils sont pris en compte par la Constitution a ark 54. Leur place dans la hiérarchie des normes à une distension doctrinale :
- Pour certains, la Constitution est au-dessus des traités
- Pour d'autres, la Constitution est en-dessous des traités

Les traités occupent une place intermédiaire : ils doivent respecter la Constitution et lorsqu'ils sont régulièrement ratifiés et applicables, ils priment sur les lois internes. Le Conseil Constitutionnel s'est déclaré incompétent piur apprécié la conformité des lois internes aux traités (décision du 15/1/75). La CCas par un arrêt en chambre mixte (réunion de plusieurs chambres) le 24/5/75 (« Café Jacques Vabre »), suivit par le Conseil d'État dans un arrêt du 29/10/89 (« Nicolo »), se sont reconnus compétents pour procéder au contrôle de conformité d'une loi interne postérieure aux traités. Le contrôle de conventionnalité permet aux juridictions judiciaires et administratives d'écarter une loi interne contraire à un traité. Lorsque la loi est à la fois antérieure et non-conforme, le traité prime en l'abrogeant. Parmi les sources internationales du droit, il y a la Convention Européenne des Droits de l'Homme (signée à Rome en 1950 et ratifiée par le France en 1974). Le respect de cette convention est assuré par la CEDH installée à Strasbourg. La mission de la CEDH est de faire appliquer la Convention et de sanctionner les violations commises par les États du Conseil de l'Europe vis-à-vis du texte de la Convention. La CEDH peut notamment condamner un État à modifier sa législation ou sa jurisprudence parce qu'elle est non-conforme à la Convention.
Ex : la CEDH a condamné la France pour violation du droit au respect de la vie privée parce que la CCas refusait les demandent des transsexuels concernant leurs changements de prénoms et de sexe sur les Actes de l'État Civil. En 1992, la France a admis ce changement.

3- Le droit de l'UE

Le droit de l'UE trouve notamment son origine dans le traité de Rome de 1957. Son application est assurée par une juridiction : la CJUE (avant CJCE = Cour de Justice des Communautés Européennes) à Luxembourg. Elle veille à l'application du droit de l'UE.

B- La Loi et les règlements

La Loi peut être comprise dans deux sens, au sens large et au sens strict. Au sens large, c'est tout texte jusk écrit qui émane d'une autorité compétente. Au sens strict, c'est l'acte voté par le parlement. La Loi est réglementée à ark 34 de la Constitution. Elle ne peut intervenir que dans des matières limitativement énumérées.
Le domaine du règlement est régi à ark 37 de la Constitution. Ce sont « toutes les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi ».
Le Conseil Constitutionnel veille au respect de cette répartition. En censurant notamment la pratique des cavaliers législatifs. Alr or, une disposition insérée (généralement par amendement) dans un texte de loi mais qui n'a rien à y faire. Depuis sa décision du 30/3/2006, le Conseil Constitutionnel se saisit d'office des cavaliers législatifs. Cela témoigne de l'importance que le Conseil Constitutionnel entend conférer dorénavant à la qualité rédactionnelle de la loi. Cela signifie qu'il ne veille pas seulement au respect des domaines respectifs de la loi et du règlement, parce que depuis quelques années déjà le Conseil Constitutionnel oblige le législateur a respecter certains principes relatifs à l'écriture de la loi. Le point d'orgue a été atteint avec la décision du 16/12/1999 qui a fait de l'accessibilité et de l'intelligibilité de la loi un objectif de valeur constitutionnelle. Une loi complexe n'est pas nécessairement inconstitutionnelle, si elle demeure suffisamment précise et intelligible pour ses destinataires. Alr or, pour être qualifié de loi, un texte ne doit pas seulement respecter la procédure constitutionnelle qui a été prévue pour son élaboration. En effet, ce texte doit aussi posséder d'autres caractères considérées commes

des objectifs de valeurs constitutionnelles par le Conseil Constitutionnel, soit des standard que le législateur doit respecter. Ces objectifs ont une valeur infraconstitutionnelle mais supralégislatives. La loi doit être normative, claire, accessible, intelligible sans être simpliste. À côté de la dégradation rédactionnelle des lois, beaucoup d'auteurs dénoncent une véritable inflation législative et un changement dans la conception de la loi. Ils dénoncent le fait qu'aujourd'hui la loi n'est plus seulement un commandement répondant à une nécessité sociale mais devient un instrument politisé voir un simple outil de communication qui serait plus orienté vers la satisfaction d'une demande sociale de loi que vers celle d'un réel besoin normatif. Il y a eu une telle dégradation de la loi que certains auteurs qui affirmaient que « les lois sont nécessaire à la société parce que la condition humaine est essentiellement pécheresse. Le droit est indispensable parce qu'il porte le glaive et que c'est seulement par le glaive que peut être domptée l'agressivité inhérente aux êtres humains, que peut être établi un ordre, un compromis fut-il précaire entre l'avidité des uns et la convoitise des autres » (Doyen Jean Carbonnier dans la première édition de son ouvrage). Dans la seconde édition de son ouvrage, il ajoute un chapitre intitulé « leçons de loi » qui est rédigé à l'impératif. Dans ce chapitre il dit « n'accepte de faire de loi que si tu y croit, non pas à la loi mais à la nécessité d'en faire une ». L'utilité sociale peut dépendre de la demande sociale mais s'il s'agit juste de suivre, ce n'est plus gouverné. Portalis qui a rédiger le Code Civil disait que « l'office de la loi est de fixer par de grandes vues les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquences et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ».

09 octobre

C- La coutume

C'est une source de droit non écrite. Dans l'ancien droit, les règles de droit avaient en grande majorité une origine coutumière. Le problème de cette origine est que cela varie selon les différents territoires. La France était divisée en deux grandes zones, l'une avec l'application de coutumes et de l'autre les territoires étaient soumis au droit romain. La diversité des coutumes et l'incertitude relative à leur application a conduit à la rédaction des coutumes. À côté de la coutume se trouvait le droit canonique, les ordonnances royales et la doctrine. Le tout a conduit à dégager petit à petit de grands principes généraux. La jurisprudence ne doit pas non plus être oubliée. De 1789 à 1804 s'applique le droit intermédiaire et lui succède la codification napoléonienne. Le Code Civil de 1804 n'est pas le seul à avoir été élaboré. Il y a aussi eu le Code de Procédure Civile, le Code de Commerce, le Code Pénal et le Code d'Instruction Criminelle. Encore aujourd'hui, la coutume a une influence en droit français.
Définition : « la coutume est une pratique de la vie juridique qui présente un caractère habituel et qui de ce fait tend à se poser comme règle de droit ».
La coutume est différente des usages. En droit, l'usage évoque une pratique qui peut ne pas avoir de portée juridique mais les usages et la coutume peuvent se rejoindre, notamment lorsque l'usage devient coutume. Pour qu'une coutume existe, il faut deux éléments cumulatifs :

- Un élément matériel - réside dans le comportement suivi de manière habituelle. Cela suppose donc nécessairement qu'une pratique ancienne ait été constamment répétée.

- Un élément psychologique - la croyance que l'usage considéré est une règle de droit obligatoire.

Il est parfois difficile de prouver l'existence de la coutume car elle nest pas écrite. Et pas de preuves, pas de droit.
Le droit admet donc que la preuve de la coutume puisse s'établir par tout moyen (écrit, témoignage…). La preuve sera apportée par celui qui entend en bénéficier. Le droit n'ignore pas la coutume et même la prend parfois en compte. En effet, il arrive que le droit renvoie expressément à la coutume. Dans cette hypothèse, la coutume est dite « secundum legem ». C'est le cas en matière contractuelle avec ark 1194 du Code Civil.
Il arrive également que la coutume comble une lacune de la loi. Dans ce cas, la coutume est dite
« praeter legem ». Ex : l'adage romain « la fraude corrompt tout ».
Enfin, il arrive que la coutume contredise la loi. On parle de coutume « contra legem ». Ex : ark 931 du Code Civil oblige les donations devant notaire. La coutume permet de donner de main à main. C'est accepter.

Il faut distinguer la coutume des principes généraux du droit. Ces principes sont difficiles à circonscrire même s'ils sont cités par le préambule de la Constitution de 1946. Ce préambule évoque « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république ». Ils constituent un fondement de censure des lois utilisé par le Conseil Constitutionnel. Le Conseil d'État fonde parfois également ces censure sur le fondement de ces principes. En effet, il a reconnu l'existence de principes généraux du droit applicable même en l'absence de textes. On voit également cette reconnaissance au niveau de la CJUE. Elle a consacré les principes de non-discrimination, de subsidiarité…
La naissance de ces principes généraux du droit est controversée. Pour certains auteurs, les juges ne font que constater l'existence de ces principes sans les créer. Pour d'autres auteurs (dont la prof), les juges créent de toute pièce les principes généraux du droit (PGD).

cours.unjf.fr cf coutume

II- Les sources officieuses
A- La jurisprudence

Le terme de jurisprudence a de nombreux sens (12). L'un des plus usités est celui qui signifie « l'ensemble des décisions rendues par les cours et les tribunaux ». Le terme est également utilisé pour désigner une certaine façon de juger, de trancher une question, un litige. Dans ce sens là, la jurisprudence est la tendance des tribunaux et des cours de trancher une question juridique toujours dans le même sens. On parle alors de jurisprudence constante. On parle au contraire de revirement de jurisprudence lorsqu'après avoir pris l'habitude de trancher une question toujours dans le même sens, les juges adoptent la solution contraire. En France, les juges ne sont pas liés par les solutions adoptées précédemment. Alr or, ils peuvent parfaitement adopter une autre solution et même si l'affaire est semblable. En France, contrairement aux pays anglo-saxons, il n'existe pas de système de *precedents* ou de *case law*. Dans les pays anglo-saxons, cette règle conduit les juges à adopter, sauf exceptions, la solution précédemment donnée par d'autres juges. Les juges français doivent à chaque fois respecter un devoir d'amnésie. Ils doivent recréer le raisonnement à chaque fois. Contrairement aux pays anglo-saxons, le système judiciaire français ne donne pas au juge le pouvoir de créer des regjus. Ark 5 du Code Civil le précise

en interdisant « aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leurs sont soumises ». Cela interdit les arrêts de règlements (création d'une loi). Alr or, les juges doivent à chaque fois rejuger les faits qui leurs sont soumis et donner une solution sans se contenter de simplement calquer la solution déjà donnée dans ce genre d'affaires.
Montesquieu disait des juges qu'ils ne sont que « la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés qui n'en peuvent modérer ni la force ni la rigueur ». Cela signifie que les juges ne font qu'appliquer les textes de lois sans les créer.

Tout cela est exact mais il est possible de considérer que la jurisprudence est une source officieuse du droit parce qu'il arrive que les juges créent de véritables regjus voir qu'ils bâtissent de toute pièce un régime jusk entier. Ex : la responsabilité du fait des choses (ark 1242 du Code Civil).
Ce mouvement a tellement pris de l'ampleur et est tellement visible aujourd'hui, que les auteurs ont créé un terme pour ça : la légisprudence.

B- La doctrine

On désigne sous ce terme les auteurs de droit et ceux qui expriment une opinion jusk qu'ils soient universitaires, magistrats ou avocats par exemple. Il arrive même que les juges reprennent des formules, des idées ou des théories jusk créées par la doctrine. Ex : la distinction créée par (René) Demogue entre les obligations de moyen (pas d'engagement à résultats mais a tout faire pour) et les obligations de résultat (engagement à un résultat) / (Christian) Mouly créé la distinction en matière de cautionnement entre l'obligation de couverture (être caution jusqu'à la fin du contrat) et l'obligation de règlement (si appel au remboursement).
Toutes ces distinctions ont été créées par la doctrine et consacrées par la jurisprudence jusqu'à devenir des distinctions incontournables. Celle de Demogue a été consacrée pour la première fois dans un arrêt rendu par la 1ere Ch. Civil de la CCas le 20/5/36. Celle conceptualisée par Mouly l'a été dans un arrêt de la 2e Ch. Civil de la CCas le 2/6/2004.

Thème 6 : le sens du droit.
Qui donne, qui précise, qui explique le sens du droit ?

Le législateur crée les lois. En choisissant les termes qui forment l'énoncé de la loi, le législateur conditionne déjà l'interprétation de la loi. Le juge est lié par les termes ainsi choisis. Malgré les termes choisis par le législateur, le juge n'est jamais pieds et poings liés par l'énoncé de la loi. En effet, il fait nécessairement œuvre d'interprétation, soit parce que les termes choisis permettent une certaine souplesse, soit parce que les termes choisis font références à des notions floues à contenu indéterminé (ex : bonne foi, bonnes mœurs, ordre public…). Même si ces notions sont floues, et donnent donc une certaine marge de manœuvre au juge, le langage de la loi conditionné nécessairement la marge de manœuvre dont bénéficie le juge dans l'application de la loi. La notion de bonne mœurs illustre parfaitement cette marge de manœuvre. Plus précisément, la règle d'assemblée plénière de la cour de cassation rendue le 29/10/2004 (n°03-11.238). Dans cet arrêt, la CCas a opéré un revirement de jurisprudence et a finalement considéré que la donation faite par un mari adultérin à sa maîtresse n'est pas contraire aux bonnes mœurs. Les juges atténuent la jurisprudence désormais, en trois temps. L'interprétation est inhérente au travail du juge. On

ne peut pas la dissocier. Pour certains auteurs, appliquer la regjus est l'interpréter, nécessairement. Certains auteurs comme Kelsen vont encore plus loin et considèrent qu'appliquer un texte de loi c'est le créer. Sans aller jusque-là, il arrive que le texte de loi nécessite d'être interprété parce qu'il manque de clarté, ark 4 du Code Civil interdit d'ailleurs le déni de justice. Cet ark dispose que « le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ». Alr or, cela signifie que le juge ne peut pas prétexter que la loi manque de clarté pour refuser de l'appliquer ou de se prononcer. Il a donc le devoir de juger et de créer le droit lorsqu'il est inexistant ou pas clair, mais que dans le cas qu'il traite et à ces conditions. À cet égard il existe une maxime qui postule que « l'interprétation cesse lorsqu'un texte est clair ». Cette dernière règle est valable pour les lois ou les actes administratifs et la CCas a récemment accepté qu'elle s'applique aussi en matière de Conventions Collectives dans un arrêt rendu par la Ch. Social le 25/3/2020 (n°18-12.467). La CCas à affirmer que la Convention Collective devait être interprétée comme la loi.
Il y a une exception : si l'application d'un texte clair aboutit à une absurdité, alors le juge doit l'interpréter. Cela a été affirmé par la 1ere Ch. Civil de la CCas le 11/5/2017 : « si toute recherche de la volonté du législateur par voie d'interprétation est interdite au juge lorsque le sens de la loi tel qu'il résulte de sa rédaction n'est ni obscur ni ambiguë et doit par conséquent être tenu pour certain, il y a exception si l'application du texte aboutit à quelque absurdité ».
Arrêt du Tribunal Civil de la Seine du 24/4/1952 : un décret interdisait au voyageur qui prenait le train « de monter ou de descendre lorsque le train est complètement arrêté ». Le texte est clair mais absurde. Dans ce jugement les juges ont affirmés que « attendu que toute recherche de volonté du législateur […] » (idem que 2017).
Si le rôle du juge est de tranché un litige en appliquant des regjus, même dans l'hypothèse où ces règles sont obscurs, incomplètes ou contradictoires, il n'est pas totalement abandonné à son sort. Il existe plusieurs principes pour aider le juge a déterminé le sens de la loi mais il faut avant tout retenir qu'en France le juge tranche le litige conformément aux regjus qui lui sont applicables. Cela signifie que le juge n'a pas le droit de juger en équité. Mais ce principe connaît quelques exceptions.

16 octobre

I- Pourquoi interpréter le droit
A- L'obligation de trancher le litige

Il serait faux de croire que le législateur peut tout prévoir et ce serait contre productif. Cela conduirait nécessairement à une sclérose de la loi, en effet, le temps nécessaire à l'élaboration de la loi coïncide très mal avec la rapidité d'évolution de la société et de ses mœurs. S'il est dangereux d'essayer de tout prévoir, il est tout aussi dommageable de vouloir enfermer les juges dans un carcan trop rigide. Dès l'instant où l'on exige du juge qu'il tranche les litiges quoiqu'il arrive on doit lui permettre d'interpréter la loi pour l'adapter à la situation. Dans le même sens, l'éventuelle absence de la loi ou son manque de clarté, va nécessairement obliger le juge à chercher des règles et des principes qu'il devra interpréter pour les appliquer au litige. La première réponse à la question de pourquoi interpréter le droit réside dans l'obligation du juge de trancher le litige selon les regjus quoiqu'il arrive.

Pourquoi n'interpréter que le droit ?

B- L’application par principe des regjus

Dernière phrase de ark 12 du CPC : les regjus applicables au litige. Cela signifie que le juge doit appliquer la loi telle qu’elle a été voulue par le législateur, mais également l’ensemble des regjus et pas que la loi. Cela veut surtout dire que le Juge ne peut pas remplacer librement les regjus par sa conception personnelle du juste. Donc il est interdit au juge de remplacer les règles applicables par ce qu’il considère être juste. Il lui est donc interdit de statuer en équité. Il arrive que le législateur autorise le juge à juger en équité. Ark 270 du CC autorise le juge à refuser d’accorder une prestation compensatoire à l’un des ex-époux lorsque l’équité le commande au regard de certains critères. Ce genre d’ark est très rare. Mais cette autorisation constitue une exception. Le principe demeure l’application des regjus.
Il arrive que les juges éprouvent des difficultés pour déterminer les regjus applicables. Dans ce cas là, il ne sont pas laissés à l’abandon et peuvent s’aider de plusieurs techniques.

II- Les méthodes d’interprétation
Il existe plusieurs méthodes dont les deux suivantes.

A- L'école de l’exégèse
Suivant ce courant de pensée, l’interprétation de la loi se révèle à partir de l’étude du vocabulaire employé, de la grammaire, de la structure de la phrase. Suivant cette méthode, les réponses se trouvent toutes dans le CC donc il suffit de l’analyser. Cette méthode a surtout eu cours au XIXe. Donc la règle litigieuse devrait être découverte en essayant de trouver le sens que le législateur a voulu lui donner. Cette recherche du sens s’appuie sur les travaux préparatoires qui sont censés renseigner sur la justification de reg (= la règle), sur son sens et sur sa portée. Tous ces documents éclairent le contexte et les objectifs du texte. Cette recherche est critiquée à la fin du XIXe notamment par François Gény qui lui reproché de conférer au fétichisme de la loi écrite et codifiée. Il dit également que l'on prête au législateur des intentions qu’il n’a peut-être jamais eu. Donc il a proposer sa propre méthode : la libre recherche scientifique

B- La libre recherche scientifique
Pour F. Gény l’interprétation est possible mais il faut que le juge se limite à ce que le législateur a prévu et non pas essayer de deviner ce qu'il est censé avoir voulu. Dans l’hypothèse où il est impossible d’interpréter parce que la situation est inédite et donc imprévue, il faut recourir à la méthode de la libre recherche scientifique. Alr or, il faudra construire une solution en s’inspirant des données historiques, rationnelles voire des considérations d’équité. Cette méthode n'est pas synonyme d’arbitraire. Pour Gény, cette méthode se veut scientifique, méthodique et argumentée.

III- Les maximes d’interprétation
(Maximes à connaître par cœur)
Il existe un certain nombre de maximes d’interprétations qui vont aider le juge.

- Specialia generalibus derogant

La maxime Specialia generalibus derogant. Cela veut dire que la loi spéciale abroge la loi générale et ancienne sur le point qu’elle régi. Alr or, une reg spéciale écarte dans son domaine la règle générale incompatible avec elle. Dérogation et abrogation ne se

confondent pas. En effet, la règle générale peut rester en vigueur et continuer à s'appliquer en dehors du domaine spéciale qui est régi par la loi spéciale. (Ex : arrêt 1e Civ. CCas 9/3/2016 n°15-18.899 et 15-19.652)

- Generalia specialibus non derogant

L'adoption d'une loi générale nouvelle n'abroge pas en principe une loi ancienne spéciale. Generalia specialibus non derogant. Alr or les domaines des deux lois coexistent, mais la loi générale cède le pas à la loi spéciale lorsque les critères de son application sont réunis.

- Ubi lex non distinguit

Une autre maxime latine importante postule qu'il est interdit de distinguer la ou la loi ne distingue pas. Ex : arrêt Ch. Soc. CCas 30/9/2020 n°19-12.885.

IV- Les raisonnement jusk

Il existe trois sortes d'arguments d'interprétation tous reliés par l'idée que la loi exprime une volonté raisonnable. Alr or, l'interprétation est guidée par la raison de la loi (ratio legis). On doit donc rechercher la ratio legis d'un texte et en déduire les conséquences.

A- Le raisonnement a pari

Alr or par égalité ou analogie. Le premier de ces arguments conduit à étendre une reg prévue pour un cas à un autre cas qui s'en rapproche mais qui n'as pas été prévu par la loi. Ex : ark 11-1 du CC dit qu'il y a des règles pour les contrats et que les autres actes jusk les respectent aussi si les cas se rapprochent.

Ça sert à adapter la loi suivant sa raison d'être. Alr or, raisonnement par analogie consiste à proposer pour situation non-expressément réglée, la solution prévue pour une situation comparable, parce qu'elle présente une même raison de décider. Il y a une limite : la ressemblance doit porter sur un élément pertinent. Ce travail est souvent fait par les juges mais il y a des domaines dans lesquels cette comparaison est strictement interdite. L'un d'entre eux est la matière pénale où il y a le principe d'interprétation stricte de la loi pénale.

B- Le raisonnement a fortiori

Alr or à partir de ce qui est le plus fort. Cela permet d'étendre la loi a un cas qu'elle n'avait par prévue en prenant en considération les raisons en vue desquelles la loi a été adoptée.

C- Le raisonnement a contrario

Alr or à partir du contraire. Cela permet de considérer que le contraire de ce qui est prévu dans la loi en est exclu. Ex : ark 6 CC. Cela permet donc de revenir au principe en matière contractuelle de liberté contractuelle.

Même lorsque le juge doit interpréter la loi, voire même lorsque le juge est obligé de créer une norme parce qu'il n'y a pas de loi applicable, ce juge ne bénéficie pas d'une totale liberté.

V- Une liberté d'interprétation encadrée

L'interprétation qui est faite par le juge est nécessairement conditionnée. Alr or, il n'y a pas à craindre l'arbitraire du juge. Son interprétation reste guidée, voire encadrée par la prise en compte de considérations pragmatiques, sécuritaires et systémiques. En premier lieu,

l'interprétation reste encadrée par le choix des termes du législateur. Le choix des mots traduit un équilibre entre précision et souplesse. Les notions de bonnes fois ou de bonnes mœurs permettent d'adapter l'application du droit à des situations variées. Ces notions laissent une marge d'appréciation au juge qui doit expliquer comment il les applique. Interpréter ne signifie pas légiférer librement. Ark 5 du CC interdit les arrêts de règlement. Cette interdiction n'empêche pas certaines décisions (notamment de la CCas) de dégager des interprétations qui vont orienter les solutions futures. Le raisonnement du juge doit s'inscrire dans le droit applicable et respecter les exigences du procès. La motivation permet d'exposer les raisons de la solution. Les voies de recours vont permettre de pouvoir la contester. Toutes ces garanties encadrent le pouvoir du juge sans supprimer les éventuelles divergences d'interprétation.

Métaphore de Dworkin :
Cet auteur, pour parler de cette restriction, a créé une métaphore, celle du roman à la chaîne. Pour cet auteur, les juges sont dans une situation comparable à celle d'un groupe d'écrivains qui serait contraint d'écrire un roman à la chaîne. Chacun, a l'exception du premier, a l'obligation d'ajouter un chapitre personnel à l'intrigue tout en respectant bien entendu une certaine continuité de style ou de contenu. Sur le plan du droit, cette conception se traduit par la nécessité d'interpréter la loi non seulement en conformité avec l'ensemble des sources en vigueur, mais aussi à la lumière des principes éthiques et politiques dont le juge croit devoir faire application. Appliqué au droit, le roman à la chaîne souligne la recherche d'une interprétation cohérente avec les textes, les décisions antérieures et les principes qui sous-tendent le système jusk. Il ne faut jamais oublier l'importance du langage de la loi. Certains auteurs ont même observé que ce langage correspond à un authentique choix de législation. L'obligation qui est imposée à la loi d'être générale et abstraite, lui interdit de régler chaque situation avec précision. Donc cette nécessité se traduit par l'usage de notions floues à contenu indéterminé (bonne mœurs, ordre public…). Ces notions permettent de fixer en cadre et d'adapter la reg, de la faire évoluer. En choisissant les termes qui sont susceptibles de véhiculer le mieux possible la notion qu'il veut utiliser, le législateur fixe un point d'équilibre entre sécurité jusk et besoin de souplesse du droit.

Thème 7 : le droit à partir de quand et jusqu'à quand ?

Le système jusk n'est pas figé donc les normes évoluent constamment. Donc à force de changement, il y a des reg parfois contradictoires qui sont adoptées. Il faut savoir lesquelles appliquer. Il faut donc étudier deux aspects relatifs au temps : le temps de la loi (sa durée de vie) et la loi dans le temps (ses modalités d'application).

I- Le temps de la loi

A- La naissance de la loi : l'entrée en vigueur de la loi

Le principe veut que les lois n'entrent en vigueur qu'une fois qu'elles sont promulguées et publiées.

- La promulgation

Les lois stricto sensu, alr or celles votées par le parlement, ne deviennent exécutoires qu'à partir de leur promulgation par le Pdt de la République. La promulgation est très importante car c'est à partir de cette date que la loi devient exécutoire.

- La publication

La loi stricto sensu et les règlements ne sont obligatoires pour les citoyens qu'à partir du moment où ils sont connus d'eux. Cette connaissance s'effectue via la publication au JO. Cette exigence de publication est absolue pour les lois, les ordonnances et les décrets.

- La date d'entrée en vigueur :

Aux termes de ark 1 du CC, les conditions de cette entrée en vigueur sont variables :
1- Le texte nouveau peut fixer lui-même sa date d'entrée en vigueur. Elle doit nécessairement être postérieure à la date de publication au JO.
2- Si rien n'est prévu dans la loi, son entrée en vigueur intervient le lendemain de sa publication.
3- Il faut réserver le cas où l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles nécessite des mesures d'application. Alr or le cas où la mise en œuvre de la loi exige des décrets d'application. Dans cette hypothèse là, l'entrée en vigueur de la loi est reportée à la date d'entrée en vigueur des décrets d'application.

Dès l'entrée en vigueur de la loi s'applique l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ».

B- L'abrogation de la loi

La loi a vocation à durer sans limitation de temps. C'est le caractère permanent de la loi. Même s'il peut exister des lois temporaires (expérimentation). Alr or, tant que la loi n'a pas été abrogée par une autre loi, elle reste en vigueur. L'abrogation peut être expresse ou implicite. Elle est expresse lorsqu'un ark de la loi nouvelle indique que le texte ancien est abrogé. Elle est implicite lorsque, sans indiquer qu'elle les abroge, les dispositions de la loi nouvelle contredisent la loi ancienne.
L'abrogation d'une loi peut-elle s'effectuer par désuétude ?
L'opinion majoritaire postule que la désuétude ou l'établissement d'un usage contraire n'entraîne pas en droit l'abrogation de la loi. En fait, la désuétude de la loi prouve simplement la défaillance des autorités à la faire respecter. Cette disposition en droit n'est pas corrélée dans la réalité. En fait, beaucoup d'exemples contraires peuvent être avancés. C'est précisément pour lutter contre la multiplication des lois inutiles, obsolètes ou désuètes, que le Sénat a mis en place une mission dite "balai" (Bureau d'abrogation des lois anciennes et inutiles) en 2018. Cela a permis d'abroger de nombreuses lois. La loi BALAI 1 à abroger une cinquantaine de lois adoptées entre 1800 et 1940. La loi balai 2 a abrogé cent-quinze lois adoptées entre 1941 et 1980.
Pendant longtemps, on a considéré que seul le législateur avait compétence pour abroger les lois qu'il avait créées. Et l'introduction de la QPC a fait bouger les lignes (62-2 de la Constitution). Le Conseil Constitutionnel a usé de son pouvoir de contrôle de constitutionnalité a posteriori dans une décision du 30/7/2010 et celle du 6/10/2010 pour considérer qu'ils pouvaient choisir de reporter la date de l'effet abrogatif de la déclaration d'inconstitutionnalité lorsque l'abrogation immédiate du texte était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

II- La loi dans le temps

Il faut s'interroger sur le domaine d'application dans le temps de deux lois successives. Alr or, il faut savoir à quelle situation la loi nouvelle s'applique. Cette difficulté est souvent

résolue de façon expresse par la nouvelle loi, laquelle contient des dispositions transitoires. En l'absence de dispositions transitoires, on applique les dispositions de ark 2 du CC, à savoir que « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'as point d'effets rétroactifs ». Le doyen (Paul) Roubier (prof de droit) à distinguer deux principes dans cette ark : la non-rétroactivité de la loi nouvelle et l'application immédiate de la loi nouvelle. La première proposition signifie que la loi nouvelle ne s'applique pas aux situations jusk qui sont déjà nées et dont les effets se sont entièrement et définitivement sous l'empire de la loi ancienne. La seconde proposition s'applique aux situations qui sont nées après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La difficulté surgit lorsqu'il faut appliquer la loi nouvelle a des situations jusk en cours, alr or qui sont nées avant la loi nouvelle mais qui continuent encore de produire des effets après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

A- L'absence d'effets rétroactifs
1- Le principe

- La loi nouvelle n'atteint pas les conditions d'acquisition ou l'établissement d'une situation jusk qui a été antérieurement créée sous l'empire de la loi ancienne.
- La loi nouvelle n'atteint pas les effets passés, alr or les effets qui ont été définitivement réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. La non-rétroactivité est un principe d'ordre public que le juge peut appliquer d'office.

2- Les exceptions
(À connaître par cœur)

Certaines lois sont rétroactives par nature.

a- Les lois interprétatives

Ces lois viennent éclairer le sens d'une loi antérieure. Donc elles rétroagissent au jour de l'entrée en vigueur de la loi qu'elles interprètent.

b- Les lois pénales plus douces

Alr or les lois pénales qui suppriment ou qui réduisent une peine. Elles ont un effet rétroactif parce qu'elles vont s'appliquer à des infractions commises avant leur entrée en vigueur mais qui n'ont pas encore été jugées. Cette rétroactivité in mitius (= en faveur de / en mieux) a valeur constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel se fonde sur ark 8 DDHC pour énoncer que « le fait de ne pas appliquer aux infractions commises sous l'empire de la loi ancienne la loi pénale nouvelle plus douce revient à permettre au juge de prononcer les peines prévues par la loi ancienne et qui, selon l'appréciation même du législateur, ne sont plus nécessaires. » Ce principe a valeur constitutionnelle est limite à la matière pénale. En matière civile ce principe n'as pas de valeur constitutionnelle et ne s'impose donc pas au législateur, ce qui n'empêche pas la CCas de s'appuyer sur la CEDH pour imposer au législateur de ne faire des lois rétroactives que s'il y a d'impérieux motifs d'intérêt général.

c- Les lois expressément rétroactives

Certaines lois ont un effet rétroactif. Le législateur peut prévoir expressément que la loi sera rétroactive. Mais pour cela, il faut que la loi réponde à des motifs impérieux d'intérêt général.

Le pouvoir exécutif ne peut pas édicter des règlements rétroactifs. Les lois rétroactives sont très rares. La loi du 27/7/1940 est rétroactive. Elle prévoit une immunité de responsabilité des chemins de fer pour les transports effectués après le 10/5/1940. Aujourd'hui on assiste à une multiplication des lois dites de validation. Elles ont pour objet de valider rétroactivement des actes passés et qui devraient être déclarés nuls lorsque le prononcé de cette nullité peut troubler l'ordre social.

B- L'effet immédiat de la loi nouvelle

1- Le principe

La loi nouvelle s'applique immédiatement à la constitution et à l'extinction de situations jusk postérieures à son entrée en vigueur. De même qu'elle s'applique à la naissance et à l'extinction de situations jusk en cours de constitution ou en cours d'extinction. Mais elle n'aura aucun effet sur les effets passés d'une situation jusk définitivement réalisée au moment de son entrée en vigueur. La loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation jusk née antérieurement à son entrée en vigueur.

2- Les exceptions
a- Les contrats en cours

En principe, la loi nouvelle n'a aucun effet sur les contrats en cours. C'est une « bulle contractuelle ». Par principe, la loi qui régit le contrat est la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

b- Une prévision expresse du législateur

Il peut décider, pour des motifs tenant à d'impérieux motifs d'ordre public, que la loi nouvelle s'appliquera même aux contrats conclus antérieurement. Le juge peut aussi décider d'appliquer immédiatement une loi nouvelle à un contrat en cours s'il y a une impérativité particulière. Dans le même sens, les effets légaux du contrat sont également régis par la loi nouvelle (ce qui ne dépend pas de notre volonté).

Thème VIII : le droit jusqu'où ?
La géographie du droit

23 octobre